

se llamarán servidumbres personales, frente a las servidumbres del período clásico, que ahora se las llama prediales o reales.

A pesar de esa unificación sistemática existen significativas diferencias entre las servidumbres prediales y las personales.

Servidumbres personales	Servidumbres prediales
Establecidas en beneficio de una determinada persona.	Establecidas para una objetiva y permanente utilidad de un fundo vecino.
Temporales: se extinguen, en principio, con la muerte del titular.	Perpetuas.
Pueden tener como objeto bienes muebles o inmuebles.	Sólo tienen como objeto inmuebles.

- Cuando se habla de la servidumbre predial o real como de un vínculo de sujeción de un fundo a otro, para beneficio y utilidad de éste último, no debe entenderse que la relación jurídica se ha establecido entre los dos fondos: esa relación jurídica —como todas— sólo puede establecerse entre personas, en este caso entre el propietario del fundo dominante y el del sirviente; son ellos los que tienen respectivamente el derecho de ejercitar y el deber de tolerar el ejercicio de la servidumbre y entre ellos se desarrollaría una eventual *vindictio servitutis* (reivindicación de la servidumbre). El carácter real de la servidumbre predial consiste en que titular y gravado no son individualizadas personas sino cualquiera que eventualmente devenga propietario de uno u otro fundo: son los fondos —*res* (cosa)— o, mejor dicho, la titularidad de ellos, lo que determina a los sujetos activo o pasivo de la servidumbre.

De todos modos resultaron comunes a las dos categorías los siguientes principios, formados en relación con una u otra.

(A) *Nulli res sua servit* (para nadie hay servidumbre de la cosa propia). En el derecho de propiedad va a confundirse el derecho real limitado cuando coinciden en un mismo titular.

(B) *Servitus in faciendo consistere nequit* (la servidumbre no puede consistir en un hacer). Lo que la servidumbre impone al propietario del fundo gravado es un padecer o soportar (*pati*) el ejercicio de la servidumbre, o un no hacer (*non facere*).

- La servidumbre *oneris ferendi* (de soportar la carga), que imponía al propietario del fundo sirviente el tener en buenas condiciones el muro para que se apoyara el edificio del fundo dominante, no es, en realidad, una excepción, pues por ella no se obliga a efectuar reparaciones sino a dejar o mantener el muro en las mismas condiciones originales.

(C) *Servitus servitutis esse non potest* (no puede haber servidumbre de una servidumbre). Este principio se originó en la imposibilidad de establecer un usufructo sobre una servidumbre predial (*fructus servitutis*).

SERVIDUMBRES PREDIALES

Son derechos reales sobre cosa ajena consistentes en una sujeción jurídica permanente de un fundo en provecho o beneficio de otro. Derechos, por lo tanto, transmisibles, en su aspecto activo y pasivo, a los sucesivos propietarios del fundo dominante y del sirviente, respectivamente, como cualidades inherentes e inseparables de los fondos.

Las servidumbres debían ser (A) útiles, (B) inalienables, (C) indivisibles, (D) de causa perpetua, (E) posibles y (F) perpetuas.

- (A) Las servidumbres prediales, por ser constituidas en beneficio de un fundo o edificio, sólo podían ser ejercitadas en la medida de la estricta utilidad de éste. Por ejemplo, si la servidumbre es de pasto o de abrevadero, sólo comprenderá las necesidades de las bestias utilizadas en el cultivo del fundo dominante y no la de los rebaños que quisiera introducir el propietario de éste.
- (B) La servidumbre es inherente al fundo; por lo tanto, se transmite con éste y no puede enajenarse separadamente.
- (C) La servidumbre no puede surgir ni extinguirse por partes. Ante cualquier causa o situación de división del fundo dominante o sirviente, cada parte del dominante tendrá derecho a la completa servidumbre y cada parte del sirviente deberá soportarla por completo.
- (D) Los fondos deben presentar condiciones objetivas tales como para que la utilidad sea permanente. Toda situación transitoria o artificial escapa al ámbito de la servidumbre. Por ejemplo, si toda el agua que puede brindar un fundo a otro consiste en un depósito llenado artificialmente, es decir por el trabajo del hombre, y destinado obviamente a agotarse con el uso, no hay lugar a una servidumbre de provisión de agua.
- (E) El ejercicio de la servidumbre debe ser posible, para lo cual pue-

de ser indispensable la contigüidad o vecindad de los fundos, aunque no suficiente. Verbigracia, en el caso de una servidumbre de acueducto entre fundos separados por un camino público, se necesitaría la concesión del estado para que el acueducto atravesase la vía pública.

- (F) En el período clásico se excluían las servidumbres temporáneas, en buena medida porque la *mancipatio* o la *in iure cessio* constitutivas eran negocios que no admitían condiciones ni términos temporales. En el derecho justinianeo, y sobre la base de estipulaciones, se permitirán cláusulas resolutorias de la servidumbre.

El Derecho Romano conoció no la categoría general y abstracta de la servidumbre predial, sino un repertorio típico que, arrancando de las cuatro rústicas primitivas, fue ampliándose a medida de las empíricas necesidades. La constitución de tipos fijos de servidumbres debe conciliarse con las modificaciones que como modos de la servidumbre (*modus servitutis*) introducen las partes, especialmente cuando la manera más corriente de establecer servidumbres fue a través de una *stipulatio*.*

CLASIFICACION DE LAS SERVIDUMBRES PREDIALES

La distinción se basa en la diferente función y estructura de cada servidumbre: son rústicas las que responden a exigencias agrícolas de la producción de frutos; son urbanas las que corresponden a exigencias edilicias de sostén, iluminación, vistas, en favor de un edificio.

TIPOS DE SERVIDUMBRES

Servidumbres rústicas. — Las más antiguas fueron las tres de paso —*iter*, derecho de pasar a pie o a caballo; *ductus*, de arrear el ganado; *via*, de transportar materiales con carro a través de un camino construido dentro de ciertas medidas— y la de acueducto: derecho de derivar agua o conducirla a través del fundo sirviente.

- Estas servidumbres habrían sido en sus orígenes, según doctrina que se está imponiendo, no derechos sobre cosa ajena, sino verdaderos casos de *mancipium** —tal vez concurrente con el del titular del fundo— sobre la franja de terreno del sendero, camino o acueducto.

- Por ello, tal vez, fueron consideradas *res mancipi* y pudieron ser usucapidas hasta la *lex Scribonia*.
- Tal vez, también por ello, las palabras *iter*, *ductus*, *via* y *aquae ductus* designaban tanto el derecho como la materialidad sobre la cual aquél recaía.

Otras servidumbres rústicas se refieren al pastoreo o abrevadero de bestias empleadas en el cultivo del fundo dominante, a la extracción de creta o arena en la medida estricta de las necesidades del fundo dominante, etcétera.

Servidumbres urbanas. — Las más frecuentes fueron las de dejar caer del techo el agua pluvial directamente sobre el fundo sirviente; las de desagües; las de apoyar o introducir vigas en el muro del fundo sirviente; las de asegurar luz y vistas, con la abstención de construir a más de cierta altura o distancia, etcétera.

CONSTITUCION DE LAS SERVIDUMBRES

I. Según el *ius civile*, las servidumbres deben ser constituidas (A) por ciudadanos romanos, (B) sobre *ager romanus*, es decir sobre fundos itálicos, y (C) por medios idóneos —los mismos actos traslativos del *dominium*: *mancipatio* para las antiguas rústicas, consideradas *res mancipi*; e *in iure cessio* para las demás.

- También el propietario de dos fundos, al alienar uno de ellos, puede hacerlo *deducta servitute* (deducida una servidumbre), es decir, constituyendo una servidumbre en favor del fundo alienado o del que conserva y a cargo del otro.
- Algo similar podía hacerse por medio de un legado *per vindicationem*.*
- También el *iudex* podía, en una acción divisoria —*actio communi dividundo** y *familiae erciscundae**—, *adiudicare servitutem*, es decir, constituir una servidumbre entre fundos resultantes de la división.
- En la época de la vigencia del *usus* se podía adquirir una servidumbre por *usucapio** luego de un año ininterrumpido de ejercicio. A fines del período republicano, una *lex Scribonia* lo impedía.

II. Además de los modos de constitución de servidumbres propios del *ius civile*, el pretor admitió otros. Especialmente en el caso de los fundos provinciales —a los que eran inaplicables

50

aquellos modos civiles— se reconocieron servidumbres establecidas *pactionibus et stipulationibus* (con pactos y estipulaciones), es decir, con el acuerdo de voluntades en la forma de estipulaciones.

III. Desaparecidas la *mancipatio* y la *in iure cessio* al cesar la distinción entre fundos itálicos y fundos provinciales, la *stipulatio* * queda como modo general de constitución de las servidumbres.

IV. Reconocidas por el derecho justiniano las posesiones de derechos (*possessiones iuris* o *quasi possessiones* *), la *traditio* * —sujeta a todos sus requisitos, entre ellos la posesión— sirve para constituir servidumbres: la *traditio* se concreta con tolerar (*pater*) el dueño el ejercicio de la servidumbre y con su intención de concederlas.

V. Justiniano aplicó también a las servidumbres la institución de la *praescriptio longi temporis*, con los mismos requisitos exigidos respecto de las cosas corporales.

DEFENSA DE LAS SERVIDUMBRES

Se obtiene el reconocimiento de la servidumbre por medio de una *vindicatio servitutis* (reivindicación de servidumbre), llamada por Justiniano *confessoria*, por contraposición a la *actio negatoria*.

Ya se ha visto, por lo demás, que en el derecho justiniano, considerando el ejercicio de hecho de una servidumbre como una *quasi possessio*, se estructura toda una tutela interdictal prescindiendo de la existencia de un derecho de servidumbre.

EXTINCION DE LAS SERVIDUMBRES

La servidumbre predial tenía carácter perpetuo porque no podía contener en sí ni plazo ni condición resolutoria; pero podía extinguirse por ciertos hechos sobrevinientes.

(A) Por confusión, cuando ambos fundos llegaran a encontrarse bajo el *dominium* de una misma persona.

(B) Por renuncia, concretada en la abstención de defensa frente a una acción negatoria.

(C) Por el *non usus*, aunque como el *ius civile* no admite que un derecho se pueda perder por no haberlo ejercitado, se entiende que, por el contrario, es el dueño del fundo sirviente quien, poseyéndolo como libre durante el plazo de 10 ó 20 años de la *praescriptio longi temporis* *, lo adquiere en esa condición de libre. En consecuencia, la servidumbre se extingue no por el *non usus* de ella, sino por el *usus* del fundo sirviente como libre.

- * La servidumbre rústica no se extingue por modificaciones naturales de los fundos; permanece latente, a la expectativa de que se restituya el estado primitivo.
- * Las servidumbres urbanas, en cambio, se extinguen con la destrucción del edificio sirviente, salvo que se lo demuela para volver a construir en el mismo lugar.

SERVIDUMBRES PERSONALES

Con esta denominación sistemática, en oposición a las servidumbres prediales o reales, el derecho justiniano comprende los siguientes *iura in re aliena*: usufructo, uso, *habitatio* y *operae servorum*.

USUFRUCTO

El usufructo (*usufructus* o *fructus*) es un derecho a percibir para sí los frutos de una cosa ajena, dejando a salvo su sustancia, es decir, sin poder alterar la estructura ni el destino económico de la cosa.

I. El origen de esta institución de la época republicana se debió al propósito del testador de asegurar a determinadas personas —especialmente a su esposa no *in manu*— un disfrute de bienes suficiente para la subsistencia mientras vivieran, pero dejando a sus herederos la propiedad de esos bienes.

II. Reconocida a una persona el derecho de percibir los frutos (*fructus*), había que presuponer un cierto poder de manejo (*usus*) de la cosa: "*fructus sine usu esse non potest*" ("no puede haber disfrute sin el ejercicio de un poder de manejo"). De todos modos, ese *usus*, ejercitado con pleno reconocimiento del *dominium* del propietario, no podía configurar una posesión; era, pues, una simple tenencia de la cosa fructífera.

III. Al titular de la *nuda proprietas* —como se llamó al *dominium* al que se le había deducido o desgajado un usufructo— le quedaba el derecho de disponer de la cosa y aun de gozarla en los límites en que no obstaculizase el *usus* y el *fructus* del usufructuario.

IV. El usufructuario hacía suyos, por percepción, los frutos: las crías de los animales sí, pero no los partos de las esclavas; las adquisiciones resultantes de los servicios del esclavo sí, pero no de las herencias o legado recibidos por éste, los que al igual que los partos de las esclavas pasaban a pertenecer al nudo propietario.

V. Las características del usufructo son (A) su correlación con el destino económico de la cosa, (B) su carácter personal y (C) temporal.

(A) Correlación con el destino económico de la cosa. — El destino dado a la cosa por el propietario era el encuadre del derecho del usufructuario, quien debía ejercerlo como *bonus vir* (varón probo). Así, pues, el usufructuario no podía producir cambios en la estructura o destino económico de la cosa, aun cuando fuera para mejorarla: no podía construir edificios, ni talar un monte para hacer sementeras, ni excavar galerías mineras, etcétera.

- * El derecho justiniano, sin embargo, extendió las atribuciones del usufructuario permitiéndole obras que mejoraran el valor reidual de la cosa.
- * De esa necesidad de preservar la esencia o sustancia de la cosa resultó que el derecho de usufructo no cayera sino sobre cosas no consumibles, es decir, las que no perecen con el primer uso.
- * Se acostumbró garantizar con una estipulación pretoriana la conservación de la sustancia de la cosa y la restitución de ésta a la finalización del usufructo.

(B) Carácter personal. — En razón de su conexión con una persona, la servidumbre terminaba cuando aquélla dejaba de existir o cuando sufría una *capitis deminutio*.

Ese carácter personal implicaba la no transferibilidad del derecho, aunque podía cederse el ejercicio del derecho, *perceptio fructuum* (percepción de frutos), pero supeditado a la muerte del usufructuario o al plazo que se le había concedido.

Además, por su original finalidad alimentaria, no se concebía, al principio, en favor de personas jurídicas.

(C) Carácter temporal. — El usufructo, o estaba constituido a término, o duraba hasta la muerte del usufructuario.

- * Extendido el usufructo a las personas jurídicas, Justiniano les fijó el plazo máximo en cien años.

Régimen del usufructo. — En términos generales, los modos de constitución y extinción y los medios procesales guardan estrecha analogía con los de las servidumbres prediales.

- * Conviene destacar el usufructo legal —es decir, impuesto por ley— del *paterfamilias* sobre el *peculio adventicio* de sus *fili*.

Cuasi usufructo. — El usufructo, por su requisito de dejar a salvo la esencia o sustancia de la cosa, sólo tuvo como objeto cosas no consumibles. Tanto era así, que en el caso de usufructo sobre un patrimonio, o una cuota parte de un patrimonio, se consideró no incluidas en el usufructo las cosas consumibles. Pero, por un senadoconsulto de la época de Tiberio, se estableció que también éstas podían ser comprendidas en el usufructo de un patrimonio establecido por legado. En tal caso, el legatario usufructuario recibía en propiedad esas cosas y daba caución de restituir otro tanto igual cuando llegara el término del usufructo.

- * Esta variante —verdadera derogación del principio básico del usufructo— se denominó, en el derecho justiniano, *quasi usufructus* y se extendió a las cosas no consumibles pero deteriorables.
- * Por cierto que la situación del quasi usufructuario era la de un mutuario. Por eso, sin necesidad de exigirle la previa caución, se actuaba

Ed

contra ellos con las acciones tuteladoras del mutuo: la *actio certae creditae pecuniae* o la *condictio certae rei*.

USO

El *usus sine fructu* (ejercicio del poder de manejo pero sin disfrute) de una cosa —fructífera o infructífera— consistió en la facultad de usar una cosa dentro de los estrechos límites de las necesidades propias o familiares.

Difería del usufructo no porque estuviera excluida la percepción de frutos, sino porque no otorgaba derecho a la totalidad de los frutos; sólo lo otorgaba a aquello *quod ad victum sibi suisque sufficiat* (que sea suficiente para la subsistencia suya y de los suyos).

- Justiniano llegó a permitir que el usuario pudiera dar en locación parte de una casa dada en uso si ésta era de mayor amplitud que la necesaria.

El régimen del derecho de uso es idéntico al del usufructo.

HABITATIO

Era, en la época de Justiniano, un derecho real que facultaba a su titular a habitar una casa de otro y aun a darla en locación a terceros.

- En el derecho clásico se discutía si se trataba realmente de un derecho real o de crédito, y en el primer caso si se asimilaba al de usufructo —con derecho de alquilar la casa— o al de uso —sin ese derecho, al menos en el período clásico.

OPERAE SERVORUM

También en el derecho justinianeo era un derecho real que facultaba a valerse de la actividad (*opera*) de esclavos ajenos y aun a locarla.

- Los juristas clásicos lo habían asimilado al usufructo, Juliano al uso. Justiniano lo consideró —como a la *habitatio*— una institución distinta "de especial naturaleza".

DERECHOS REALES PRETORIANOS

Llamados así porque tuvieron su origen en la protección dada por el pretor a ciertas relaciones. Se dividen en dos grupos: el de derechos reales de goce, formado por la enfiteusis y la *superficies* —que constituyen una superación del rígido concepto de *dominium*; al estructurarse, más que como derechos reales limitativos del señorío del propietario, como señorío prevalente sobre el de éste último—, y el de derechos reales de garantía, formado por el *pignus* en sus dos variantes: la *datio pignoris* (entrega de la prenda) o prenda y la *conventio pignoris* (convención pignoratícia) o hipoteca.

ENFITEUSIS

La institución clásica que aparece como antecedente para que Justiniano conformara, de acuerdo con necesidades y prácticas del mundo heleno-oriental, el derecho real de enfiteusis, fue la *possessio* del *ager vectigalis**, concedida por el estado o los municipios en forma permanente siempre que se pagara el canon establecido, y fue considerada por unos juristas como resultado de una compraventa, y por otros, de una locación. Parece haber prevalecido esta última postura, pero, de todos modos, se protegerá luego aquella *possessio* con una acción real —*actio vectigalis*—, análoga a la *reivindicatio*, con lo que quedó asimilada a la *possessio del ager tributarius** y *stipendiarius**, verdadero derecho real que constituye la propiedad provincial*.

64 504 1

63

Sobre ese antecedente y el de una antigua institución griega relativa a tierras públicas incultas, concedidas con la obligación de cultivarlas y pagar un canon, Justiniano estructura la enfiteusis, oscilando entre un concepto de propiedad y otro de derecho real sobre cosa ajena.

El nombre de enfiteusis, que significa en griego plantación, recuerda aquel antecedente, aunque en la institución justiniana no se iba a exigir el cultivo del fundo.

La doctrina discutió sobre la índole jurídica del *ius emphyteuticum*: si se lo asimilaba a una venta, el peligro de disminución o destrucción de la productividad del fundo pesaba sobre el enfiteuta; si se lo asimilaba a una locación, ese peligro recaía sobre el dueño. El emperador Zenón dispuso que si no había pacto contrario la destrucción total perjudica al concedente y la parcial al concesionario que debe seguir pagando íntegramente el canon.

La enfiteusis, concesión perpetua o a largo plazo de un fundo, confiere un derecho real de goce similar al del usufructo, pero con las siguientes diferencias.

(A) El enfiteuta puede transformar o alterar las condiciones o el destino económico del fundo; no el usufructuario, que debe dejar a salvo su sustancia o esencia.

(B) El usufructo se extingue con la persona de su titular; en cambio la enfiteusis es transmisible a los herederos y puede ser cedida, siempre que se haya ofrecido una preferente opción al nudo propietario para que pueda quedarse con la enfiteusis por el mismo precio ofrecido por ella o recibir un dos por ciento de ese precio —*laudemio*.

(C) El enfiteuta adquiere todos los frutos separados —no sólo los percibidos, como ocurre con el usufructuario— y, además, los incrementos o mejoras, como si fuera el propietario y en abierta oposición al clásico principio de *superficies solo cedit* (la superficie hace parte del suelo).

(D) El enfiteuta debe pagar un canon anual, con la alternativa de perder su derecho si no paga durante tres años.

SUPERFICIES

La propiedad romana importaba el principio básico de que todo lo construido sobre el suelo pertenecía al propietario de éste; nuestra propiedad horizontal es incompatible con ese principio. Pero, con el antecedente de concesiones de construir y gozar de edificaciones sobre suelo público y de la correlativa tutela interdictal del pretor, se estructuró en el derecho justiniano un derecho sobre suelo ajeno —la *superficies*—, que también, como la enfiteusis, tenía algunos caracteres propios de un derecho de propiedad y otros propios de un derecho real sobre cosa ajena.

- Aquellas concesiones, extendidas a fundos privados, se habían constituido como locaciones por las cuales el superficiario actuaba con la *actio conducti* contra el concedente o sus derechohabientes. Pero el pretor comenzó a proteger al concesionario contra terceros perturbantes de su derecho con un interdicto especial de *superficiebus* análogo al *uti possidetis*.
- En el derecho justiniano se le otorgó también una acción real —*actio quasi in rem* y se le extienden todas las defensas jurídicas dadas en favor y contra un propietario por relaciones de vecindad.

La *superficies* vino a resultar así un derecho real de total y estable goce de un edificio a favor de quien lo había construido y pagaba un canon anual llamado *solarium* —de *solum* (suelo).

PRENDA E HIPOTECA

Frente a los otros derechos reales sobre cosa ajena, consistentes en derechos limitados de goce, la prenda y la hipoteca son considerados derechos reales de garantía, pues, constituidos sobre una cosa, están dirigidos a ejercer presión sobre su dueño para llevarlo al cumplimiento de una prestación debida y vinculan esa cosa con la eventual satisfacción —indirecta— del crédito a través de ella.

Handwritten mark: "Hd"

I. La primera garantía real entre los romanos fue la *fiducia* —vocablo derivado de *fides*: buena fe, lealtad, confianza—. Consistía en la alienación de una cosa —por las formas solemnes de la *mancipatio* y la *in iure cessio*— hecha *fiduciae causa* (con la finalidad de la *fiducia*), lo que entrañaba la obligación —exigible con la *actio fiduciae*— de restituir la cosa al mancipante o cedente, una vez pagada la deuda que se había quedado garantizar.

El acreedor podía vender la cosa si había sido autorizado a ello con un *pactum de vendendo* (pacto de venta); debía dar al deudor todo lo que el precio excediera la deuda garantida —*superfluum*—. Si no mediaba ese pacto y la vendía, era responsable por la cosa ante la *actio fiduciae* que podía poner en juego el deudor.

II. Pero fueron constituyéndose luego otros vínculos reales aptos para garantizarle al acreedor la satisfacción indirecta de su crédito sin necesidad de la transmisión de la propiedad: la prenda y la hipoteca.

III. La prenda (*pignus*) consistió al principio en la simple entrega de la tenencia de una cosa mueble o inmueble al acreedor, permaneciendo para el deudor la propiedad o la *possessio ad usucapionem*.

- * Esta situación de hecho, protegida por interdictos del pretor —recuérdese que esta hipótesis del *pignus* era uno de los casos anómalos de posesión interdicial— no possibilitaba que con una misma cosa pudieran estar garantidos distintos acreedores. Este inconveniente se superó a través de una evolución de la garantía de la relación contractual entre un locador y un *conductor* (locatario) de fundos.

IV. Era costumbre que los esclavos y otros elementos necesarios para la agricultura introducidos por el locatario en el fundo arrendado fueran vinculados en *pignus* para la garantía del alquiler.

El pretor protegió esa garantía, primero con el interdicto Salviano, para darle al locador la posesión de esos bienes mientras estuvieran en el fundo arrendado, y luego con la acción Serviana, para reclamar esa posesión si los bienes habían ido a parar a manos de un tercero.

V. Luego, con la posterior extensión de esta acción —con la correspondiente designación de *quasi Serviana*— a cualquier otra constitución en garantía, quedó perfilada frente al *pignus*, basado en la entrega de la cosa en garantía al acreedor, la *conventio pignoris* (convención de prenda) o —como se la llamó más tarde, con vocablo griego— *hypotheca*, que tenía la misma misión que ese *pignus* pero que no requería la transmisión de la cosa al acreedor. La *actio quasi Serviana, pignoratitia in rem* o *hypothecaria*, promovible contra terceros que hubieren entrado en posesión de la cosa objeto de la convención de prenda, consagraba el carácter real —oponible *erga omnes*— de ese derecho de garantía.

Prenda e hipoteca recaían, pues, indistintamente sobre bienes muebles o inmuebles y con el mismo carácter de garantía real: la única diferencia es que la última no requería la entrega de la cosa al acreedor. Por ello, la hipoteca resultó de más práctica y frecuente utilización respecto de los inmuebles.

CONSTITUCION DE LA PRENDA Y DE LA HIPOTECA

Ambas presuponen un crédito simple, o a término, o condicional, y pueden ser constituidas no sólo por el deudor, sino también por un tercero.

Objeto de ellas podía ser cualquier cosa mueble o inmueble *in commercio*. Pero en el derecho justiniano también los derechos reales sobre cosa ajena —servidumbres, usufructo, enfiteusis, *superficies* y aun otro *pignus*— llegaron a ser objeto de la prenda y la hipoteca.

En principio, se constituían, como todos los *iura in re aliena*, por convención entre las partes.

- * Podían constituirse por disposición del tribunal en caso de ejecución de sentencia —*pignus in causa iudicati captum*—. Las misiones* en pos-

65

504 11

65

sessionem, antiguo medio extraprocesal del pretor, se adaptaron a esa función de garantía con el nombre de *praetorium pignus*.

- En la época posclásica, con frecuencia la ley estableció implícitas (*ta-cita*) hipotecas que gravaban todo el patrimonio del deudor en garantía (A) de los créditos del estado por impuestos, (B) de pupilos y menores*, (C) de la dote de la mujer y (D) de la eventual indemnización por daños en inmuebles dados en enfiteusis por la Iglesia.

DERECHOS DEL ACREEDOR PIGNORATICIO E HIPOTECARIO

El acreedor pignoraticio cometía *furtum usus** si usaba o gozaba de la cosa, entregada sólo en garantía de su crédito.

Al constituirse la prenda solía incluirse la cláusula *com-missoria**, por la que, no satisfecho oportunamente el crédito, el acreedor quedaba propietario de la cosa prendada. También solía pactarse el *ius distrahendi*, es decir que, en la eventualidad de no cumplimiento de la prestación, el acreedor pudiera vender la cosa para pagarse y restituir el excedente (*superfluum*) al deudor.

La primera cláusula —*lex commissoria*— fue declarada nula por Constantino, pero el *ius distrahendi* se hizo tan inherente a la prenda que Justiniano lo consideró esencial y el acreedor pudo ejercerlo —aun mediando un pacto en contrario— siempre que previamente al deudor se lo instara en tres oportunidades a pagar.

- Si no se presentaba ningún comprador, el acreedor podía pedirle al emperador que le fuera dada en propiedad la cosa, pero en tal caso, el deudor podía rescatarla en el plazo de dos años.
- El acreedor pignoraticio en posesión de la cosa ve extendido su derecho de prenda a los frutos percibidos y aun al parto de la esclava. Podía convenirse que los hiciese suyos como contrapartida de los intereses de la deuda —*antichresis*—; de lo contrario, debía su valor ser descontado de los intereses y de la deuda, quedando el eventual resto para el deudor.
- El acreedor satisfecho debía restituir la cosa prendada al constituyente —deudor o tercero—, pero, por una disposición del emperador Gordiano, pudo retenerla en garantía de un crédito de mutuo no garantido pignoraticamente.

En la hipoteca —*pignus* sin desplazamiento de la posesión— era posible que la cosa —generalmente un inmueble—

podiera garantizar deudas a varios acreedores. En ese caso, regía para los acreedores el principio *prior tempore, potior iure* (primero en el tiempo, prevalente en el derecho), por el cual cada acreedor podía hacer valer su derecho después de satisfecho el del acreedor precedente en cuanto al tiempo de haberse constituido la garantía real.

- Pero una hipoteca en garantía de un préstamo para reparar la cosa tuvo prevalencia sobre las demás, sin atención a la fecha de constitución.
- Afirmado en el derecho posclásico el criterio de la publicidad, se dio absoluta preeminencia al *pignus publicum* —escrito en actas oficiales— y al suscrito por tres testigos.

EXTINCION DE LA PRENDA Y DE LA HIPOTECA

Se extinguían por el cumplimiento total de la prestación, pues si era parcial, subsistía por entero la garantía pignoratícia.

Extinguíanse también por la venta de la cosa por parte del primer acreedor, por renuncia, por prescripción y por confusión* de las calidades de acreedor y propietario. También se extinguían, naturalmente, por la destrucción de la cosa. Pero si se trataba de un edificio, la garantía pignoratícia continuaba en vigor sobre el nuevo edificio que en el mismo sitio se levantara.

CAPITULO X

OBLIGACIONES
EN GENERAL

La construcción que los romanos hicieron de las obligaciones representa uno de los temas que más influencia van a tener en el derecho occidental posterior.

A diferencia de otros pueblos, donde todo lo relacionado con este tema aparece con un grado más o menos acentuado de indefinición y primitivismo, los romanos van a construir una noción de obligación muy robusta y clara, la cual fue capaz de dotar a los negocios que se realizaban de una seguridad admirable.

Sin embargo, para comenzar a entender el siguiente significado de la obligación romana debemos ante todo despojarnos de la idea vulgar existente acerca de que cualquier noción de lo que podemos entender por deuda implique o agote el contenido de la *obligatio*.

La noción de *obligatio* —vocablo derivado de *ligare* (unir, atar)— da la idea de un vínculo, de una atadura, de una ligazón de constreñimiento jurídico de una persona respecto de otra. Por ello, quizá, lo que más sorprenda al estudiante son las exigencias formales que existieron desde los comienzos de Roma para que ese vínculo se considerara realmente formado.

Ello, por otra parte, es lo que le dará a la obligación romana ese carácter tan fuerte de personalización, que recorrerá prácticamente todas las etapas de su evolución histórica y que ofrecerá las principales objeciones para concebir la cesión de créditos

64

504 1

65

y de deudas, procedimientos referidos a una época posterior en que, precisamente, ese carácter personalista estará más debilitado.

CONCEPTO DE OBLIGACION

La obligación (*obligatio*) es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor (*debitor*) se encuentra constreñida a tener que cumplir una determinada prestación a otra persona denominada acreedor (*creditor*).

- * La célebre definición de las "Instituta" establece que la obligación es "el vínculo jurídico en virtud del cual nos encontramos constreñidos a tener que pagar alguna cosa, conforme al derecho de nuestra ciudad".
- * Generalmente, esta definición es criticada por cuanto si bien hace mención del deudor, no lo hace en cambio del acreedor. Digamos que lo que querían establecer los romanos era la "situación jurídica" del deudor, y en este sentido es evidentemente una *obligatio*. En cambio, si tal situación la definimos desde el ángulo del acreedor —tal la costumbre del derecho moderno—, estaríamos ante el "derecho de crédito" que tiene el acreedor para constreñir al deudor al pago de una prestación. Pero esto ya no sería estrictamente romano.

I. Lo importante de la obligación es la situación de constreñimiento. Dicha situación consta de dos elementos: el débito y la responsabilidad.

Por débito (*debitum*; o bien para la doctrina alemana, *Schuld*) se entiende el aspecto de la prestación debida, como, por ejemplo, el deber de entregar 100 sestericios o de hacer una zanja.

La responsabilidad (*Haftung*), en cambio, es propiamente la situación de sujeción jurídica en la cual se encuentra el deudor.

Por ejemplo, en el caso de alguien que celebre un *nexum** obligándose a pagar una bestia de carga —digamos, un buey—, los juristas romanos distinguirían entre el deber de entregar el buey (*debitum*) y el vínculo de sujeción nacido del mismo *nexum*.

Si el deudor hubiera pagado el buey, habría cumplido lo debido, pero continuaría la responsabilidad, la cual sólo se extinguiría con un rito exactamente contrario al *nexum*, como lo era la *solutio per aes et libram** (liberación por medio del cobre y la balanza).

II. En cuanto a la prestación, ésta puede consistir en un *dare*, en un *praestare* o en un *facere*.

- * El término *dare* se refiere al transpaso al acreedor de la propiedad u otro derecho real sobre la cosa. Así, por ejemplo, en el mutuo —préstamo de consumo— hay un *dare*, por cuanto se debe transpasar el dominio de la cosa fungible prestada.
- * El término *praestare*, en cambio, indica el hecho, en forma genérica, de tener que entregar una cosa, pero sin necesidad de transpasar su dominio: verbigracia, obligarse a entregar una cosa en garantía (*pignus*); o bien como ocurre en el comodato, que es un préstamo de uso.
- * El término *facere*, finalmente, se refiere a toda prestación que signifique la realización de un acto positivo —en sentido genérico, incluido el *dare*—, pero más restrictivamente cuando se refiere a un mero hacer, como en la locación de servicios o en la locación de obra.

EVOLUCION DE LA OBLIGACION ROMANA

I. Las obligaciones más antiguas son aquellas que tienen su fuente en hechos ilícitos, es decir que resultan de la comisión de un delito (*delictum*), pero haciendo referencia a los *delicta privata* (delitos privados) y no a los *crimina publica* (delitos públicos).

- * La reparación de estos *delicta privata* parece haber seguido una evolución de la cual quedan todavía rastros en la ley de las XII tablas. De este modo, en una primera etapa, el perjudicado por un delito podía ejercer su venganza privada con la aprehensión del cuerpo mismo del agresor, incluso ejecutándolo. Posteriormente, se aplicará para determinados casos la ley del talión, por la cual se podía tomar represalias contra el agresor con un daño equivalente al que había recibido el agredido. Más adelante aún, la reparación de estos delitos se efectuará por la redención del derecho de venganza que tenía el agredido; en virtud de éste, el propio agresor, o sus agnados o gentiles, ofrecían al perjudicado una entrega de bienes para expiar la responsabilidad. Esta evolución culminará cuando el estado regule el *quantum* de esa reparación, incluso tarifándolo de manera muy minuciosa, como ocurre en la ley decemviral. En esta última situación estamos ya propiamente en el supuesto de la *obligatio* tal como la definimos más arriba.

II. También en el derecho antiguo se conocieron algunos ritos jurídicos capaces de crear situaciones obligatorias. En realidad, fueron más bien pocos, pudiendo mencionarse el *nexum* y la *sponsio*. Más tarde aparecerá la *stipulatio*.

- * El *nexum* es un acto *per aes et libram* *; es decir, utilizando el rito del cobre y la balanza. Este rito debía suceder en presencia de no menos 5 testigos y su contenido resulta bastante obscuro, aun cuando parece ser —situación bastante controvertida— que el deudor, que era el que hablaba, se comprometía a pagar la deuda “automancipando” su propio cuerpo. Lo cierto es que si no pagaba, el acreedor podía ejercitar contra él la *manus iniectio* *.
- * La *sponsio* era un rito contractual verbal —cuyo contenido originario se lo vincula a la religión— que consistía en una pregunta, “*Spondes?*” (“¿Te comprometes?”), seguida de una respuesta: “*Spondeo*” (“Me comprometo”). Debía utilizarse necesariamente el verbo *spondere*, que por su significado ritual sólo podía ser pronunciado válidamente por los ciudadanos romanos.
- * Para poder extender la práctica contractual a los extranjeros entre sí, o bien a un romano con un extranjero, se autorizó la *stipulatio* (derivada de *stips*, brizna de paja [que se cortaba en señal de consenso]). Consistía ésta en una pregunta y una respuesta, congruentes entre sí: “*Promittis?*” (“¿Prometes?”); “*Promitto*” (“Prometo”). En este caso se podía utilizar cualquier verbo.
- * Generalmente se admite que estas primeras formas de contraer obligaciones tenían vinculaciones con la religión. Según relata Cicerón, era de mucha importancia el juramento (*iusiurandum*) por el cual alguien se comprometía por su *fides* (buena fe) en presencia de los dioses. No fue, sin embargo, una forma distinta de obligarse, sino más bien un acto que solía preceder a los contratos.

III. La responsabilidad emergente del *nexum* va a sufrir una alteración hacia el 326 a.C., cuando luego de una revuelta popular provocada por la conducta de un acreedor respecto de un deudor por el *nexum*, se aprobó la *lex Poetelia Papiria*, según la cual se habría atenuado la responsabilidad del cuerpo del deudor para permitirse, en cambio, la ejecución del patrimonio.

IV. El paso siguiente estará dado, ya en el derecho clásico, por la admisión de las obligaciones del *ius gentium* bajo la protección del pretor, de tal modo que las obligaciones podrán ser divididas en civiles y honorarias o pretorias.

CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES

Podemos distinguir las obligaciones de acuerdo a cómo sea el vínculo, cómo sean los sujetos, o cómo sea el objeto.

POR EL VINCULO

OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES

Lo normal de una obligación es que esté protegida por una *actio*, de tal modo que cuando no se cumple con la prestación, se puede demandar su cumplimiento. Pero por razones de equidad se admitieron obligaciones que carecían de *actio*: éste es el supuesto de las obligaciones naturales.

- * Acá la expresión *naturalis* se entiende como opuesta a *civilis*: es el sentido de lo “fáctico” frente a lo “jurídico”. Por ello la expresión *civilis* debemos interpretarla en el sentido omnicompreensivo de obligaciones que tengan *actiones*.

En cuanto a los supuestos de obligaciones naturales, los podemos encontrar, en general, en los créditos y en las deudas de aquellos sometidos a *potestas* —como es el caso de los *fili* y de los esclavos.

- * En realidad, lo que hizo el Derecho Romano fue trabajar sobre distintas figuras particulares, como las siguientes.
 - a) Las deudas contraídas por un esclavo *per se*, ya que si estaba autorizado por su amo, éste respondía por aquél, como en el supuesto de las *actiones adiecticiae qualitatis*.
 - b) Las obligaciones contraídas por los *fili* entre sí o respecto del *pater*, salvo el caso de los *peculios* *.
 - c) Las obligaciones celebradas por el pupilo sin la *auctoritas* de su tutor.
 - d) Las obligaciones extinguidas por la *capitis deminutio*, como en el caso de una *adrogatio*; o también las extinguidas por la *litis contestatio*.
- * Posteriormente se agregaron, en el período posclásico, otros casos, como el de una obligación celebrada por un *filius* en contra de lo dispuesto por el senadoconsulto Macedoniano * o las nacidas de un simple pacto no formal de pagar intereses.

En todos estos supuestos podemos ver que si bien las obligaciones no son jurídicamente exigibles, no obstante resulta

67

504 1

66

justificado admitir ciertos efectos basados en razones de evidente equidad.

Entre estos efectos corresponde señalar los siguientes.

- 1) Si se pagaba una obligación natural, no se podía luego repetir, por la *condictio indebiti**, lo pagado, aun cuando ese pago se hubiese efectuado por error por considerárselo exigible.
- 2) Una obligación natural podía compensarse con una obligación civil.
- 3) Igualmente, se podía novar una obligación natural convirtiéndola en obligación civil.
- 4) Podían ser afianzadas por medio de una fianza, de una prenda o de una hipoteca.
- 5) Por su carácter de naturales eran tenidas en cuenta en el cómputo de la herencia y del peculio.

OBLIGACIONES CIVILES Y HONORARIAS

Las obligaciones civiles son aquellas que reconocen su fuente en el *ius civile* y, en consecuencia, resultan protegidas por una *actio civilis*.

- * Estas obligaciones eran las más importantes en el derecho antiguo. Se distinguían de las demás porque en la redacción de la fórmula debía incluirse la palabra *oportere*: "*oportere dare, facere aut praestare*" ("es necesario dar, hacer o poner a disposición").
- * Más tarde, en los comienzos de la época clásica, se incluirán en este grupo las que corresponden a una *actio bonae fidei*°.

Las obligaciones honorarias eran las dotadas de una *actio* por el pretor.

OBLIGACIONES DE DERECHO ERICTO Y DE BUENA FE

Esta división está relacionada con otra que comentamos anteriormente: las acciones *stricti iuris* y acciones *bonae fidei*.

- * En las *obligationes stricti iuris*, como ser una *stipulatio*, sólo puede reclamarse aquello que fue estrictamente convenido.
- * En las *obligationes bonae fidei*, el arbitrio judicial tiene más juego para

su interpretación. El *iudex* trata de inquirir a la luz de la *fides*° lo que quisieron las partes, pudiendo condenar "en aquello que el demandado debe al actor según las exigencias de la buena fe" (*ex fide bona*). De este tipo son las obligaciones nacidas de la compraventa, la locación, la sociedad. También en estas últimas el juez puede incluir: a) prestaciones accesorias: —intereses, frutos— de manera más libre que en las de derecho estricto; b) pactos adjuntos no formales (*pacta adiecta*)° y, c) examinar directamente el dolo o la violencia sin necesidad de que se haya interpuesto, por ejemplo, una *actio doli*° *mali*.

- * La protección de estas obligaciones mediante las acciones *bonae fidei* representó uno de los aportes más importantes de la actuación del pretor como árbitro de la *aequitas*°.

POR LOS SUJETOS

Los supuestos prevén la existencia de una pluralidad de acreedores —aspecto activo— o de una pluralidad de deudores —aspecto pasivo—, e incluso, en algunos casos, ambas situaciones al mismo tiempo.

OBLIGACIONES PARCIARIAS

Si se trata de una pluralidad de acreedores, cada uno de éstos podrá exigir la parte que le corresponde en la obligación, la cual se divide en *pro parte* o *pro rata*. Si se trata de una pluralidad de deudores, cada uno de éstos se encuentra constreñido a pagar también su parte.

Significa, pues, que la obligación, unitaria en un comienzo, se fracciona en tantas obligaciones autónomas como partes hubiere.

- * Estas obligaciones —llamadas también mancomunadas— constituyen la inmensa mayoría. Así, por ejemplo, si hay varios coherederos, cada uno de ellos es acreedor o deudor *pro parte*.

OBLIGACIONES CUMULATIVAS

Se da en supuestos en los que existen un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un deudor. La obligación se multiplica, debiendo recibir cada acreedor la totalidad de la prestación, o cada deudor satisfacerla en plenitud.

fo

- Es el caso en que una misma persona vende separadamente la misma cosa a varias personas, obligándose por ello a la prestación íntegra respecto de cada uno de los compradores.
- O como cuando un testador ha instituido el legado de una sola cosa en favor de dos personas simultáneamente, en que para cumplirlo el heredero deberá entregar a uno de los legatarios dicha cosa, y al otro el valor estimado de la misma.
- Del mismo modo, se admitió, en la época clásica, que en caso de comisión de un delito, cada uno de los autores se obligaba a pagar la pena en forma íntegra.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS

Si existe un solo acreedor y varios deudores obligados solidariamente, puede exigirse el pago íntegro de la prestación a uno cualquiera de ellos —*in solidum*—. Pero una vez pagada, la obligación se extingue para todos.

Si existen varios acreedores y un solo deudor, puede exigirse a éste cumplir la prestación en forma íntegra para uno cualquiera de los acreedores; pero pagada a uno, se extingue el derecho de exigirla por parte de los demás.

- Para el Derecho Romano, la obligación es siempre "única", ya que la prestación debida es una sola, no obstante que en algunos textos se hable de *duae obligationes* (dos obligaciones).

Las obligaciones solidarias pueden nacer de un contrato, de un testamento o de la ley.

- En el caso del contrato, el ejemplo típico es la *adstipulatio*. En su celebración, se hace variar el sentido de la pregunta y de la respuesta. Así, en la solidaridad activa uno de los acreedores pregunta al deudor: "¿Me prometes dar 100?"; a su vez, el otro acreedor también pregunta: "¿Me prometes dar esos mismos 100?", a lo que el deudor responde: "Ya sea a uno o a otro de vosotros os prometo dar 100". En cambio, en la solidaridad pasiva, uno de los acreedores pregunta: "Seio, ¿me prometes dar 100?", y luego el otro: "Mevio, ¿me prometes dar esos mismos 100?", a lo que cada uno de los deudores contesta: "Lo prometo"; o ambos a la vez: "Lo prometemos".
- En el caso del testamento podía darse la solidaridad de un legado *per damnationem*. Esta solidaridad podía ser activa: "Que por medio de mi heredero le sean dados 100 a Ticio o bien a Mevio". Aquí, cualquiera de los legatarios podía exigir el legado al heredero. Pero también pasiva: "Que mi heredero Lucio Ticio o mi heredero Mevio den 100 a Seio", por lo cual ambos herederos resultaban obligados solidariamente. Para

evitar las dudas que se suscitaban, Justiniano exigirá claridad indubitable en el caso de la solidaridad activa, pues de lo contrario los legatarios se podían considerar acreedores parciales.

- Surgen también por la ley cuando ésta sí lo dispone, como, por ejemplo, en las obligaciones delictuales de la época de Justiniano —antes eran cumulativas—; también en el caso de las obligaciones de los fiadores —*sponsores, fidepromissores*—; lo mismo para las obligaciones de los tutores o co-tutores respecto de sus pupilos, etcétera.

En las obligaciones solidarias se plantea el problema de si el deudor que pagó tiene derecho a exigir a los otros codeudores una cuota parte de contribución; y otro tanto ocurre en el caso del acreedor que percibió la prestación, en el sentido de si puede ser obligado a distribuirla entre los coacreedores.

Este supuesto —denominado "acción de regreso"— no fue admitido durante la época clásica, ya que se entendía que la obligación era única, importando la prestación el "todo" de aquélla. Sin embargo, se la admitió siempre que entre los deudores o acreedores hubiera una relación interna que permitiera el ejercicio de una *actio*. Así, por ejemplo, si los deudores formaban una sociedad, el que había pagado podía exigir que se compartiera dicho pago por la *actio pro socio*.

- En el mismo caso se encontraban quienes podían ejercitar la *actio communi dividundo* —supuesto del condominio— o la *actio familiae erciscundae* —supuesto de la indivisión hereditaria.
- En la época posclásica se admitió la "acción de regreso", primeramente, en el caso de los cotutores, y luego Justiniano la permitió con carácter general para todos los supuestos.

OBLIGACIONES AMBULATORIAS

Se trata acá de obligaciones en las cuales el sujeto activo o el pasivo, o ambos, no están determinados en el momento de celebrarse la obligación, debiéndose no obstante la prestación por parte de o a favor de aquel que se encontrare en determinada situación.

- Así, por ejemplo, si un animal daña la cosa del vecino, la obligación existe en la cabeza de quien fuere el dueño del animal en el momento de intentarse la *actio*.
- También, la obligación de reparar el muro en el supuesto de la servi-

68

504 1



67

dumbre *oneris ferendi* * corresponde a quien sea propietario del fundo sirviente.

- Lo mismo la obligación de pagar los impuestos, que corresponderá a quien sea propietario, enfiteuta o superficiario del terreno, aun cuando atañan a períodos en que estas personas no tenían nada que ver con el inmueble.
- Se explica, a través de estos ejemplos, el carácter ambulatorio de estas obligaciones por cuanto nacen y se carga sobre un animal o un terreno con cierta independencia de quien resultare titular del dominio o derecho real.

POR EL OBJETO

OBLIGACIONES GENERICAS Y ESPECIFICAS

La obligación es genérica cuando la prestación debida consiste en objetos determinados únicamente por su género: así, por ejemplo, un caballo, un buey, diez medidas de trigo.

- Si no se ha especificado ninguna cláusula especial, el que determina la elección del objeto con que se pagará la obligación es el deudor. Si el acreedor se ha reservado la elección, le corresponderá a él. Este *ius electionis* se transmite a los herederos.
- Debido al género, la obligación se debe siempre, puesto que se considera que aquél no parece nunca, a menos que, dado un género muy estrecho, se demuestre la imposibilidad total del cumplimiento, lo cual es un caso por lo demás raro.
- Cuando la elección corresponde al deudor, éste puede pagar —en el derecho clásico— con cualquier objeto comprendido dentro del género, no importando la calidad del mismo. Justiniano, en cambio, establecerá que se debe pagar una cosa de "calidad media", de tal modo que el deudor no se libere pagando una especie mala o pésima, ni el acreedor pueda pretender una de calidad óptima.

La obligación es específica cuando la prestación consiste en un objeto claramente determinado. Así, este caballo blanco, las diez medidas de trigo que tienes en tu granero, etcétera.

- Acá ocurre que si la especie se extingue por caso fortuito la obligación también se extingue.

OBLIGACIONES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

Son divisibles las obligaciones cuando las prestaciones debidas pueden ser fraccionadas en partes —sin menoscabo de

su naturaleza o valor— a los efectos de su cumplimiento. De lo contrario, son indivisibles.

- El ejemplo más típico de obligaciones divisibles es el relativo a sumas de dinero.
- En general, las prestaciones de *dare* son divisibles, ya que en la transmisión del dominio y otros *iura in re* —con excepción de las servidumbres—, éstos se pueden constituir *pro parte*.
- En cambio, las prestaciones de *facere* son indivisibles, por la obvia consideración de la imposibilidad de su cumplimiento por partes. Existiría una excepción cuando se trata de obras o servicios que se pueden cumplir en medidas determinadas; así, por ejemplo, hacer cosas que se pueden medir, pesar o contar.
- En la época clásica a las indivisibles se las juzgó igual que a las solidarias en cuanto a su cumplimiento. Justiniano modificó este principio teniendo en cuenta las siguientes situaciones: a) si hay varios acreedores, el deudor que paga puede pedir una caución al acreedor que ha cobrado la deuda por si los otros le reclamasen; b) si hay varios deudores, el interpelado al cumplimiento puede pedir una prórroga y exigir previamente una contribución a los demás codeudores; y c) ante el incumplimiento, la obligación se torna divisible en cuanto a la indemnización de daños e intereses, la que se debe pagar *pro parte*.

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS Y FACULTATIVAS

En la obligación alternativa, la prestación es única, pero al deudor le es dada la opción de elegir para su cumplimiento entre dos o más objetos establecidos disyuntivamente. Por ejemplo: "¿Prometes darme 100 o el esclavo Sticho?"

- En principio, la elección corresponde —salvo que se disponga lo contrario— al deudor. Este *ius variandi* es transmitido a los herederos.
- Se discutió a quién correspondería el *ius variandi* en el supuesto de que el deudor hubiese pagado por error los dos objetos y luego pretendiese repetir uno de ellos. Justiniano resolvió darle la elección al deudor, avalando la opinión de Juliano y Papiniano y en contra de Celso, Marcelo y Ulpiano que se inclinaban por el acreedor.
- En cuanto a los riesgos que eventualmente pudiesen correr los objetos, se decidió que a) si por caso fortuito se extinguían todos los incluidos en la elección, también la obligación se extinguía; b) si por un hecho fortuito se extinguía uno de ellos, se debían el otro o los otros, persiguiendo el *ius variandi* —Justiniano en este caso le admite al deudor el liberarse pagando el valor estimado de la cosa extinguida—; c) si uno de los objetos se extinguía por caso fortuito y otro por culpa del deudor, éste no se liberaba sino que se veía expuesto a la *actio doli* del acreedor.

80

En la obligación facultativa, la prestación reside en un objeto determinado, pero el deudor tiene la facultad de liberarse entregando otro en el momento del pago.

- La diferencia con la obligación alternativa debemos establecerla de la siguiente manera: en ésta los objetos opcionales integran el contenido de la obligación —están *in obligatione*—; en cambio, en la facultativa hay un solo objeto, apareciendo el otro no *in obligatione*, sino *in solutione* (en el pago). Por ello es que si se extingue el objeto *in obligatione* por caso fortuito, directamente queda extinguida la obligación.
- Un ejemplo de obligación facultativa, según algunos juristas —otros entienden que de alternativa—, sería el del *pater* obligado por el daño ocasionado por el esclavo. En principio, lo que debe es la indemnización de ese daño, pero se puede liberar entregando al esclavo (*noxae deditio*).

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

CLASIFICACIONES

a) Gayo, en sus "Instituta", fue el primero en clasificar las fuentes de las obligaciones, estableciendo que éstas nacen de un contrato (*ex contractu*) o de un delito (*ex delicto*).

b) Posteriormente, en otra obra suya, "Libri rerum coticidianarum sive aureorum", agrega a la clasificación bipartita originaria un tercer cuadro de figuras que deja indeterminadas, llamándolas "*variae causarum figurae*" ("varias figuras de causas").

c) Finalmente, en Justiniano encontramos explicitadas estas figuras, a algunas de las cuales, por su cercanía con los contratos, las llama "*quasi ex contractu*"; en tanto a otras, por su parecido con los delitos, las denomina "*quasi ex maleficio*" o "*quasi ex delicto*".

En lo que resta de este capítulo examinaremos estas fuentes, salvo en lo que respecta a los contratos, que por su complejidad e importancia serán vistos de manera especial en el siguiente capítulo.

OBLIGACIONES NACIDAS DE DELITOS

Se entiende por delito todo acto ilícito que esté sancionado con una pena.

- Para resultar responsabilizado por un delito es suficiente, en cuanto a la edad, ser *impuber pubertati proximus*, pero también pueden serlo algunos que carecen de capacidad negocial, como el del esclavo o del pródigo.
- El perjudicado por el delito tiene la oportunidad de ejercitar una acción penal para conseguir el cobro de la pena, que en un principio pudo ser corporal, pero luego se convirtió en pecuniaria.
- Esta acción penal no es incompatible, en cuanto a su ejercicio, con alguna acción reipersecutoria, la cual se puede acumular. Así, por ejemplo, quien sufre el *furtum* tiene la *actio furti* —por la pena del *quadruplum* o el *duplum* del valor de la cosa—, pero además también la *condictio furtiva* y la reivindicación para recobrar la cosa.
- Esta acción penal es en principio intransmisble: no se puede ejercitar contra los herederos del delincuente ni por los herederos del perjudicado. Sin embargo, este principio fue evolucionando: por un lado, se permitió contra los herederos del delincuente por el monto de lo que éstos hubieran aprovechado económicamente; por otro, sólo fueron intransmisibles para los herederos del perjudicado las de contenido personalísimo, como la *actio iniuriarum* (acción de injurias).
- La acción penal admite el beneficio de la *deditio noxae*. Cometido el delito por un *filius* o un esclavo, es responsable el *pater*; pero éste se libera de la pena pecuniaria entregando *in causa mancipi* * al ofendido la persona del hijo o en propiedad al esclavo.

Los romanos conocieron dos clases de delitos: los públicos (*crimina* *) y los privados (*delicta* * o *maleficia*). Sólo corresponde aquí ocuparse de estos últimos.

En realidad, los romanos, más que concebir una categoría genérica y abstracta de delitos, configuraron una serie pequeña de figuras delictuales concretas, como el *furtum*, la *rapina*, el *damnum iniuria datum* y la *iniuria*.

69

504 1

68

EL FURTUM

Consiste en el apoderamiento de una cosa ajena para considerarla como propia en contra de la voluntad de su dueño.

- La figura del *furtum* se irá configurando lentamente. Por cierto que excedió lo que hoy día se conoce por "hurto" pues englobaba también otras situaciones.
- No sólo era la *amotio rei* (remoción de una cosa ajena), sino también la *retentio invito domino* (retención de una cosa en contra de la voluntad del dueño), como es, por ejemplo, el caso del depositario que se niega a restituir la cosa depositada. Por eso, para englobar ambas posibilidades, aparece la noción de *contrectatio rei* (apoderamiento material de la cosa).
- Desde la época clásica se van configurando ciertas situaciones especiales que enriquecen los caracteres del *furtum*. Así, se distingue el *furtum rei* (sustracción de una cosa) del *furtum usus* —que es usar de una cosa en contra de la voluntad del dueño, como cuando le pido prestado a Ticio un caballo para dar un paseo y me lo llevo a la guerra— y del *furtum possessionis* —que es la sustracción de la cosa propia que está por buena fe en posesión de un tercero, como ocurre cuando el deudor sustrae al acreedor la cosa dada en *pignus*—. En este último caso, como lo señala Gayo, se da la paradójica circunstancia de cometer *furtum* sobre la cosa propia (*furtum rei suae*).
- El *furtum* se integra con un elemento subjetivo configurado por el dolo (*dolus malus*); o, más específicamente, por el *affectus furandi* (voluntad de robar), o por el *animus furandi* (ánimo de robar). Algunos autores agregan la necesidad de existencia del *animus lucri faciendi* (voluntad de querer enriquecerse), que funcionaría como distinto del anterior; pero la mayoría de la doctrina los ve como sinónimos.

Clases de *furtum*. — Podemos distinguir las siguientes:

1) *Furtum manifestum* y *nec manifestum*. Es *manifestum* cuando el ladrón es sorprendido *in flagranti delicto*; es decir, en el momento mismo de la comisión, o dentro del lugar en que se cometió el delito —doctrina clásica—; o, más ampliamente para Justiniano, cuando incluso se lo ve al ladrón llevar en público o en privado la cosa robada. De no darse estas situaciones es *nec manifestum*.

- En la ley de las XII tablas el *furtum manifestum* era penado, si se trataba de un hombre libre, con azotes y adjudicación de su cuerpo al perjudicado en una situación similar a la del esclavo —*addictus*—; en cambio, si se trataba de un esclavo, era azotado y arrojado desde lo alto de la roca Tarpeia.
- Si el ladrón *manifestus* cometía el delito de noche, o bien, siendo de día, lo hacía armado, directamente se le podía dar muerte, pero debía haberse requerido previamente a grandes gritos a los vecinos.
- Estas penalidades van a ser dejadas de lado posteriormente, estableciendo el pretor en su edicto que el *manifestum* es penado con el pago del *quadruplum* —o sea, cuatro veces el valor de la cosa— y el *nec manifestum* con el *duplum*. En este último caso se conservó la misma pena que en la ley decemviral.

2) *Furtum conceptum* y *oblatum*. Algunos autores suelen llamar *furtum conceptum* los casos en que el perjudicado descubre la cosa robada en la casa de alguien mediante una pesquisa solemne —*perquisitio lance licioque*—, aunque en realidad se trataría, más bien, de la *actio furti concepti*.

Si la cosa era encontrada en la casa de alguien porque otro se la había entregado, aquél no quedaba libre de responsabilidad, pero tenía contra éste la *actio furti oblata*. A este supuesto se lo suele llamar *furtum oblatum* (hurto entregado).

- La *perquisitio lance licioque* la debía efectuar la víctima vestida solamente con un taparrabos (*licium*) y llevando en la mano un platillo (*lanx*). Este rito, posiblemente vinculado con prácticas mágico-religiosas, no ha encontrado aún una explicación convincente. Desapareció con la *lex Aebutia* (s. II a.C.) para ser reemplazado por un registro efectuado ante testigos.
- Tanto la pena del *furtum conceptum* como la del *furtum oblatum* debía ser cumplida por el *triplum*.
- Surgieron también otras acciones: la *actio furti prohibiti*, que era sancionada con el *quadruplum* cuando se impedía el registro, y la *actio furti non exhibiti*, ejercida contra quien, no obstante haberse hallado la cosa en su poder se negase a exhibirla ante el juez. Justiniano suprimirá el registro y este tipo de acciones.

Acciones que puede ejercitar la víctima del *furtum*. — Aparte de las *actiones furti* ya mencionadas —que eran puramente penales—, si la víctima era la propietaria podía ejercitar tam-

80

bién la *condictio furtiva*, que, dirigida contra el ladrón y sus herederos, tendía a lograr la restitución de la cosa si éstos hubieran aprovechado de ella.

Igualmente, el propietario víctima del robo podía ejercer la reivindicación, que contenía efectos reipersecutorios más amplios, pues podía dirigirse contra cualquiera —además del ladrón y sus herederos— que detentase la posesión de la cosa robada.

LA RAPINA

Se entiende por *rapina* la sustracción violenta cometida por una banda de hombres, si bien posteriormente se admitió que un delito era *rapina* aun cuando la sustracción la hubiese cometido un solo hombre y siempre que mediara violencia, con armas o sin ellas. Por esta razón configura un *furtum* calificado.

- Este delito tuvo su origen en los excesos realizados por grupos armados hacia fines de la República. Debido a la levedad de la pena que podía corresponderle a los autores —ya por *iniuria*, ya por el daño injusto previsto en la *lex Aquilia*—, el pretor peregrino M. Lúculo, en el año 76 a.C., creó una acción más enérgica que la del *furtum* —difícilmente se podía ser aprehendido *in flagranti delicto*— que fue la *actio vi bonorum raptorum* (acción de bienes arrebatados por la fuerza).
- Esta acción, dirigida contra el *fur improbus* (ladrón malvado), era infamante y se la podía ejercer por el *quadruplum* si se la intentaba llevar a cabo en el curso del año en que había ocurrido el hecho; en cambio, intentada después del año era por el solo valor de la cosa.

EL DAMNUM INIURIA DATUM

Se trata del daño ocasionado en forma culposa sobre una cosa ajena. Fue contemplado por la *lex Aquilia*, que, en realidad, se trató de un plebiscito propuesto por el tribuno Aquilius, tal vez a principios del siglo III a.C.

- Con esta ley se contempló en forma global el daño injusto. En la ley de las XII tablas estaban previstos sólo algunos casos, como la *actio de pauperie* (contra el dueño de un animal que ocasionare un daño), la *actio de pastu pecoris* (contra el dueño de un animal que pastare en fundo ajeno) y la *actio de arboribus succisis* (contra aquel que hiciere un corte abusivo de árboles ajenos).

La *lex Aquilia* contiene tres capítulos, de los cuales sólo el primero y el tercero se relacionan con este delito.

En el primer capítulo se establece que "quien matare injustamente a un esclavo ajeno o a un cuadrúpedo que se halle comprendido en un rebaño, sea condenado a dar al dueño tanto cuanto fuera el máximo valor que hubo tenido la cosa en ese año".

En el tercer capítulo se prevé toda otra clase de daño sobre cosa ajena, como ser el herir a los comprendidos en el capítulo primero, o la quemadura, fractura, ruptura o derramamiento de una cosa ajena. La pena consistía en pagar al dueño el máximo valor que hubiere tenido la cosa en los treinta días anteriores al daño.

- Tanto en este caso como en el anterior, la *actio ex lege Aquilia* es considerada mixta —penal y reipersecutoria al mismo tiempo—, ya que, al decir "máximo valor", eventualmente había que pagar un valor mayor al que tenía la cosa en el momento de la comisión del delito. De este modo, si el daño era sobre un esclavo que padeciese una cojera en el momento del hecho por un accidente ocurrido tres meses antes, en caso de que tal situación entrase en el primer capítulo, el valor que había que pagar era el que tenía el esclavo cuando estaba perfectamente sano. La acción era reipersecutoria hasta el precio de la cosa en el momento del daño, y penal por la diferencia con el mayor precio que pudo tener en el último año o treinta días anteriores al daño.
- El *damnum* debía ser *iniustum*; esto es, haber sido ocasionado por dolo o por culpa, aun admitiéndose que ésta fuera en grado levisimo. Así, por ejemplo, el soldado que se ejercitase con flechas en un lugar no destinado a los ejercicios de guerra e hiriese a un esclavo ajeno.
- Por otra parte, para dar lugar a la *actio ex lege Aquilia* se requería que el daño fuera *corpore corpori datum*, es decir, causado por la acción del cuerpo de alguien directamente sobre el cuerpo del animal o cosa. Se entendía que ello no ocurría si, por ejemplo, alguien encerraba a un animal ajeno y lo dejaba morir de hambre; o también si se incitaba a un esclavo propiedad de un tercero a subir a un árbol y por esta causa se fracturaba un brazo. Sin embargo, por razones de equidad, el pretor concederá *actiones utiles* o *actiones in factum* para la reparación de los daños causados en hipótesis de este tipo.

70

504 1

68

LA INIURIA

La palabra *iniuria* tiene un sentido muy amplio cuando se refiere a todo aquello que no se hace conforme a derecho. Aquí, en cambio, contempla en forma restringida toda acción física —golpes de puño, fracturas— verbal —insultos— o escrita —libelo agravante— que afecte a una persona libre.

- La *iniuria* se puede sufrir directamente o también cuando se produce sobre un hijo o hija, o descendiente, o sobre la mujer propia, por ejemplo, si se la cortejare. En cambio, no corresponde la *iniuria* sobre un esclavo, a menos que con él se pretendiera indirectamente injuriar al *dominus*.
- Se debe cometer en forma dolosa, con intención de ofender. No existiría tal intención si se hiciera *animo iocandi* (con intención de bromear). Tampoco, si por querer herir a un esclavo, se hiriera a un hombre libre.

En la ley de las XII tablas se establecía una pena especial para cada caso: para el supuesto de un miembro roto, el talión; para un hueso dañado por contusión la pena era de 300 ases si se trataba de un hombre libre, y de 150 si se trataba de un esclavo. Las otras injurias eran penadas con 25 ases.

Este sistema se tornó luego obsoleto, por lo que el pretor estableció uno nuevo que concedía la *actio iniuriarum* por el monto que estimara el actor si se trataba de una injuria leve, y por el monto determinado por el mismo pretor si se trataba de una injuria grave.

- La distinción entre grave y leve depende de las circunstancias. Así, por razón del hecho, no era lo mismo un mero exceso de lenguaje que una herida o fractura; por razón del lugar, no era lo mismo que ocurriera en privado que en el teatro o en el circo; por razón de la persona, no era lo mismo la injuria vertida contra un magistrado o un senador que contra un hombre común.
- La acción nacida de este delito se extingue por la *dissimulatio*, es decir, por el perdón del ofendido, que olvida —disimula— el ultraje recibido.
- En la época de Sila se dictó la *lex Cornelia de iniuriis* (entre los años 82 y 79 a.C.), por la cual se tipificaron formas especiales de injurias:

así, el haber sido empujado (*pulsatio*) o azotado (*verberatio*) —teniendo en cuenta aquí más la ignominia sufrida que el daño corporal— y la violación de domicilio.

- Aparte de esa acción civil de injurias se permitirá en ciertos casos la incriminación pública, de tal modo que se pudiese lograr una pena corporal; por ejemplo, en el caso en que se publicase un libelo infamante, o se injuriase al culto cristiano, o a los lugares sacros, o a los sacerdotes. La persecución civil, por un lado, y por otro la criminal, serán la regla en la época justiniana.

OBLIGACIONES NACIDAS
QUASI EX DELICTO

Debido a la existencia de ciertos hechos no previstos directamente como delitos, se fue construyendo desde la época clásica una serie de casos en los cuales el pretor concedía para su persecución acciones penales *in factum conceptae*. Su nota común es la exigencia de la culpa, aun cuando en algún caso se exige el dolo.

Estos casos —mencionados en las “*Instituta*” de Justiniano— son los siguientes.

EL SUPUESTO DEL JUEZ QUE HACE
SUYA LA CAUSA

Ocurre cuando el juez, dolosamente, se inclina por una de las partes al dictar sentencia.

- En la época justiniana se engloba, incluso, la negligencia puesta por el juez. La acción *in factum* progresa por el monto del daño ocasionado.

EL CASO DEL EFFUSUM ET DEIECTUM

Si de una habitación se ha arrojado (*effusum*) o tirado (*deiectum*) alguna cosa que ha causado perjuicio a otro, el *habitor* —sea propietario o no— debe responder —aun cuando no lo haya arrojado o tirado él, sino su hijo o su esclavo— como si fuera un delito (*quasi ex delicto*).

- Si el daño era respecto de una cosa, la acción lo era por el *duplum*; si se hubiere ocasionado la muerte de un hombre libre, la pena era de

Of

50 sólidos de oro; pero si simplemente se lo hería, el juez debía estimar equitativamente la indemnización.

EL CASO DEL POSITUM ET SUSPENSUM

Si el *habitor* de una casa —fuese propietario o no— ha puesto (*positum*) o colgado (*suspensum*) un objeto que al caer se ocasionare un daño, debe responder con una pena de diez sólidos de oro y ello ocurre con independencia de su culpabilidad.

EL SUPUESTO DEL DUEÑO DE UN NAVIO, POSADA O CABALLERIZA

Si en un navío, en una posada o en una caballeriza, alguno de los dependientes roba u ocasiona un perjuicio a quienes se encuentran en esos lugares, el dueño de los mismos —no sus herederos— deberán responder ante el perjudicado —y sus herederos— por el daño causado.

- * Se juzga acá que el dueño de esos lugares es culpable por "haberse valido de hombres malos", que son los que realmente cometieron los hechos —*culpa in eligendo* (culpa en la elección).

OBLIGACIONES NACIDAS QUASI EX CONTRACTU

La nota común de estos actos lícitos es la falta de consentimiento —requisito de los contratos—. Sin embargo, por razón de equidad, fueron dotados de acción por el pretor. Comentamos a continuación los principales casos.

LA GESTION DE NEGOCIOS

Se entiende que hay gestión de negocios (*negotiorum gestio*) cuando una persona, sin mandato de otra, realiza unilateralmente negocios útiles para aquél.

- * Según lo dice Justiniano, "esto ha sido admitido por utilidad para que los negocios de los ausentes, obligados a partir súbitamente y a toda

prisa sin haber confiado a nadie su desempeño, no quedaran en abandono, porque ninguno, sin duda, se ofrecería a cuidarlos si no tuviera ninguna acción para reclamar los gastos que en ellos hubiese hecho".

- * El gestor debe realizar en pro del dueño del negocio (*dominus negotii*) un acto que redunde en su beneficio —ya sea porque le ocasione un beneficio o le evite un daño—, como ocurre cuando se repara una casa, se cura a un esclavo, o se paga una deuda.
- * De la *negotiorum gestio* deriva la *actio negotiorum gestorum*, la cual puede tener dos formas distintas: a) la *directa*, que puede intentarla el *dominus negotii* para obtener del gestor la restitución de todo lo obtenido en la gestión, pudiendo responsabilizarlo, en caso de haber infringido su deber de diligencia, por el monto del daño ocasionado; b) la *contraria*, que puede intentar el gestor contra el *dominus negotii* para obtener la indemnización por los gastos efectuados y daños sufridos.

LA TUTELA

Justiniano asimila este caso como *quasi ex contractu*, ya que los tutores obligados por la *actio tutelae* no lo están por un contrato —no hay contrato entre el tutor y el pupilo—, pero sí por algo parecido a un contrato.

Ello tiene sentido en relación con la *gestio** del tutor, generándose la posibilidad de la *actio tutelae directa* y *actio tutelae contraria*.

EL CONDOMINIO Y LA INDIVISION HEREDITARIA

Cuando una cosa —condominio— o un patrimonio —indivisión hereditaria— está en común entre varias personas, si una de ellas efectúa un arreglo o percibe frutos, estos actos generan, el uno, la obligación de los demás de compartir el gasto; el otro, de repartir los frutos percibidos. Como aquí no hay un contrato entre las partes —el que se le aproxima es el de sociedad—, se entiende que dichas obligaciones nacen *quasi ex contractu*, es decir, como si fuera una sociedad.

EL PAGO POR ERROR

Cuando alguien paga por error una cosa no debida, o paga más de lo debido, quien ha aceptado el pago está obligado a la devolución de lo indebidamente pagado (*condictio indebiti*).

71

504 1

70

Esa obligación no nace de un contrato sino *quasi ex contractu*, como si lo dado indebidamente lo hubiera sido en virtud de un mutuo.

LOS LEGADOS

Interpreta también Justiniano que la obligación que tiene el heredero de cumplir el legado respecto del legatario no nace de un contrato —inexistente entre heredero y legatario—, por lo que anota esta obligación como teniendo su fuente *quasi ex contractu*.

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Se suele mencionar también como una fuente de las obligaciones el llamado "enriquecimiento sin causa". Estamos acá en presencia de una doctrina moderna, según la cual una persona no puede enriquecerse por una cosa que le haya dado otra sin la existencia de una causa jurídica (*iusta causa*) que así lo justifique. Los romanos, al respecto, sólo contemplaron algunos casos concretos, sin estructurar una doctrina. Esos casos, elaborados por el pretor sobre la base de concesión de las *condictiones**, serían los siguientes: a) la *condictio indebiti*, para obtener la restitución de lo pagado por error; b) la *condictio ob turpem causam* o *iniustam causam*, para lograr la devolución de una prestación hecha por causa ilícita o inmoral; c) la *condictio causa data causa non secuta*, para conseguir la restitución de una prestación que había sido hecha teniendo en cuenta un resultado futuro, cuando éste no se produce; d) la *condictio sine causa*, que engloba todos los supuestos de inexistencia de causa; e) la *condictio furtiva*, para lograr la restitución de la cosa hurtada; f) la *condictio ex lege*, cuando la ley reconoce una obligación sin indicar una acción precisa; g) la *condictio generalis*, establecida en concurrencia de las acciones nacidas de un contrato, cuasi-contrato o delito.

En realidad, las dos últimas —admitidas por Justiniano— no serían ejemplificativas, como las otras *condictiones*, de casos de enriquecimiento sin causa.

GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES

FIANZA

Una obligación puede ser garantizada por medio de garantías personales —fianza— o por medio de garantías reales —prenda* e hipoteca*. De estas últimas ya se ha tratado en el capítulo de los derechos reales.

La fianza es una obligación accesorio por medio de la cual una persona se obliga a responder con lo suyo por una deuda ajena.

- * Debido a la alta estima que los romanos tenían del honor y de la amistad, la fianza alcanzó una importancia muy grande —quizá mayor que las mismas seguridades pignoraticias— rodeándola de un halo de verdadero deber de lealtad.

En la época clásica hubo tres clases de fianzas: *sponsio*, *fidepromissio* y *fideiussio*.

SPONSIO

Como su nombre lo indica se trata del contrato verbal, que sólo podía celebrarse entre ciudadanos romanos.

- * Al fiador (*sponsor*) se le pregunta luego de celebrado el negocio principal: "¿Prometes darme lo mismo?"
- * La obligación contraída por el *sponsor* no se transmite a los herederos.

FIDEPROMISSIO

Se realizaba por medio de una *stipulatio accesorio* —para que pudiera ser celebrada por no ciudadanos—, rigiéndose por las mismas reglas que la *sponsio*.

- * Varias leyes reglamentaron en la República ambas clases de fianza. Así, la *lex Apuleia* disponía que, habiendo varios fiadores, si uno de

ellos pagaba más que su parte, podía hacerse reembolsar de los otros el excedente por medio de una acción.

- * Igualmente la *lex Furia* —que rigió sólo en Italia— limitaba la responsabilidad de esta fianza a dos años, luego de los cuales se extinguía; también se establecía que cada uno pagaba con su parte viril, y si uno de ellos era insolvente, no se cargaba sobre los demás sino que se perjudicaba el acreedor.
- * Por la *lex Ciceretia* se prescribía que el acreedor debía hacer saber públicamente la clase de crédito, el monto y la cantidad de fiadores. De lo contrario, parece ser que éstos quedaban liberados.

FIDEIUSSIO

Por medio del verbo empleado en la pregunta y respuesta —se sigue la mecánica de la *stipulatio**— se da a entender que el fiador queda obligado por su fe y lealtad.

- * A diferencia de los dos anteriores, esta institución, aparecida en el siglo I a.C., se puede emplear para garantizar todo tipo de obligaciones y no solamente las que surgen de la *sponsio* o de la *stipulatio*.
- * No estando sometidos a las leyes *Apuleia*, *Furia* y *Ciceretia*, los cofiadores —salvo regla contraria— responden solidariamente.
- * La *fideiussio* es una fianza más típica, ya que es un respaldo accesorio de la obligación principal; en la *sponsio* y en la *fidepromissio* se obligan por lo mismo que el deudor principal.
- * Por último, se transmite a los herederos.

CARACTERES COMUNES

(A) Por ser accesorias se pueden constituir por menos o igual monto que la deuda principal, pero no por más.

(B) A partir de una constitución de Adriano, el fiador tendrá, respecto de sus cofiadores, el *beneficium divisionis*: si es demandado, puede exigir que se divida la deuda en tantas partes como deudores solventes haya.

(C) En la época de Justiniano quedó sólo la *fideiussio*. Se permitió el *beneficium excussionis* (beneficio de excusión), por medio del cual el fiador podía pedir que primeramente se ejecutara al deudor principal.

(D) El fiador que paga la deuda tiene —en forma indudable desde Justiniano— derecho para dirigirse contra el deudor principal.

En la época clásica, si se trataba de la *sponsio*, tenía una *actio depensi*; si había mediado un mandato entre ambos, tenía la *actio mandati contraria*. En general, el acreedor solía ceder sus acciones al fiador que se disponía a pagar.

Justiniano otorgará con carácter genérico el *beneficium cedendarum actionum*: el fiador que paga tiene derecho a que le sea cedida la acción que tenía el acreedor contra el deudor.

TRANSMISION DE CREDITOS Y DEUDAS

La idea de que una obligación pudiera ser cedida —ya fuese por el aspecto del crédito o de la deuda— representó una noción muy difícil de aceptar en Roma. Ello era debido sustancialmente al carácter eminentemente personal que tenía el *iuris vinculum* que se trababa entre el acreedor y el deudor.

Las maneras empleadas para solucionar ciertas necesidades de transmisión de créditos y de deudas revelan las grandes dificultades existentes.

CESION DE CREDITOS

I. El modo primero que conocemos en la evolución jurídica romana fue la *novatio** cuando se operaba un cambio de los acreedores. Inducido por el acreedor A, el deudor B accedía a prometer por una *stipulatio* que le dirigía C a pagarle a éste el objeto de la prestación debida anteriormente.

- * Técnicamente, no es una cesión de crédito, ya que por los efectos novatorios el primer crédito se extinguía transformándose en la nueva obligación.
- * Tenía el inconveniente de que había que contar con el asentimiento del deudor, quien era libre de prestar el mismo o no.
- * Por otra parte, al extinguirse la primera obligación, se extinguían los accesorios —garantías, intereses—, a menos que se hubiese tomado la precaución de constituirlos nuevamente.

72

504 1

71

II. Para poder obviar estos inconvenientes se recurre al mecanismo procesal. Quien quiere transmitir el crédito designa a la persona que será la nueva acreedora como *cognitor** o *procurator in rem suam**, quedando éstos facultados para accionar en su nombre reclamando el crédito, de tal modo que una vez cobrado lo retenían para sí.

- * Por esta manera de actuar —que no necesita del consentimiento del deudor—, el *cognitor* o *procurator* hace valer en la *intentio* el crédito de quien los designó, pero luego, en la *condemnatio* —transposición de nombres en la fórmula—, figuraban ellos como beneficiarios.
- * El inconveniente es que hasta el momento de la redacción de la fórmula —*litis contestatio*— el crédito está a nombre del cedente, quien podía revocar el negocio efectuado o incluso cederlo por el mismo procedimiento a otra persona.

III. Una forma de cesión más autónoma se va a lograr en el derecho clásico a partir del emperador Antonino Pío (siglo II d.C.), ya que se otorgará al cesionario una *actio utilis*, que funcionará de manera independiente a la representación procesal. Por medio de ella ya no maneja una situación ajena, sino una situación propia —que no podía revocarse ni perderse por la muerte del cedente—. De hecho, se obtienen los mismos resultados que en la cesión de créditos actual.

- * Esta situación fue admitida por Antonino Pío en relación con la compra de una herencia al heredero. Pero luego, la hipótesis de la *actio utilis* se fue ampliando, abarcando el de compra de un crédito singular, cesión de un crédito en concepto de dote, legado de un crédito, etcétera.
- * El inconveniente que presenta es que el crédito no se desliga totalmente del acreedor cedente; de este modo, la *actio utilis* del cesionario se une a la anterior.

IV. Justiniano, mediante un trabajo de los codificadores que interpolaron una constitución de Alejandro Severo y otra de Gordiano, determinó que si mediaba una notificación —*de-muniatio*— efectuada por el cesionario al deudor, éste no se liberaba pagando al acreedor cedente, ya que debía hacerlo al cesionario. Prácticamente con ello se llega a admitir la transmisión del crédito.

- * Para impedir ciertos abusos de cesiones efectuadas a acreedores especuladores que luego se mostraban implacables con el deudor, constituciones de Honorio y Teodosio prohibieron ceder créditos a *potentiores* (personas de posición económica superior).
- * También se prohibieron las cesiones de créditos litigiosos, debiendo mencionarse igualmente una constitución de Anastasio, que favorecía al deudor, ya que le permitía liberarse pagando no el monto adeudado, sino la suma por la cual el cesionario compró el crédito al cedente.

CESIÓN DE DEUDAS

Si la cesión de créditos presentaba problemas, éstos se verán acrecentados para la cesión de deudas, ya que el *iuris vinculum* de la *obligatio* representaba una atadura o ligadura estrictamente personal.

I. Sin embargo, se podía lograr algo semejante mediante la novación con cambio de deudor —*expromissio*—, la cual representaba la extinción de la obligación primera para dar nacimiento a la nueva.

II. También se podía recurrir al mismo sistema ya señalado para la cesión de créditos de acudir a un representante procesal —*cognitor* o *procurator*— facultándolo para dejarse representar por el acreedor, de tal modo que con la técnica de la transposición de nombres la *condemnatio* recaerá sobre el que asumió la deuda.

- * Sin embargo, esta forma es mucho más insegura que la anterior —*novatio*—, ya que el deudor antiguo no quedaba liberado frente al acreedor, quien por otra parte no podía exigir al deudor nuevo, a menos que éste accediera a ser parte en el juicio.
- * Si celebrado un convenio entre el deudor originario y el nuevo, éste no respondía, el primero podía —luego de pagar la deuda— repetir contra aquél por el reembolso.

SF

CONTRATOS

Es idea normal en el derecho moderno que todo acuerdo de voluntades —salvo raras excepciones— sirve en general para producir obligaciones. Sería erróneo pensar que en Roma esto era tan sencillo.

I. En un principio, la palabra *contrahere* se aplica en un sentido muy amplio. Así, a veces tiene un sentido sinónimo a *committere* —cometer, como por ejemplo: *contrahere culpam, incestum, crimen*—. Otras veces es vocablo vecino a *constituere* —constituir, así *contrahere amicitiam* o *inimicitias*—. En cambio, *contractus* —como derivado de *contrahere*— es mucho más tardío de lo que se piensa, hasta tal punto que no figura en muchos autores clásicos —Cicerón, Tito Livio, Salustio— y sólo aparecerá en forma un tanto aislada en un texto de Varrón, quien lo atribuye al jurista Servio Sulpicio.

II. En el viejo *ius civile*, la mera *conventio* o el *pactum* no engendran obligaciones jurídicas. Para que pueda surgir la obligatoriedad será necesario que esa convención esté incorporada a un rito o solemnidad formal, que tiene la virtud de otorgarle la exigibilidad jurídica. Ello es lo que ocurre con el *nexum**; también con el contrato verbal de la *sponsio** y más tarde con el de la *stipulatio**.

III. Como consecuencia del engrandecimiento del estado romano, y en virtud de las exigencias nacidas del comercio y en general del tráfico jurídico, el pretor peregrino comenzó a reconocer —concediendo *actiones*— distintas formas contractuales del *ius gentium*, como los contratos reales y los consensuales.

IV. Ya en la época clásica, Gayo dice de cuatro formas posibles de obligarse por *contractus*: que una obligación fuese contraída como consecuencia 1) de la entrega de una cosa (*re*), 2) del pronunciamiento de ciertas palabras (*verbis*), 3) de ciertos registros por escrito (*litteris*), o 4) del solo consentimiento (*consensu*).

V. Cabe señalar, incluso, que en la época clásica el elemento *consensus* aparece en una segunda línea —no como en los consensuales— detrás de las formas o de la entrega de las cosas. Será en un texto del jurista Pedio, citado por Ulpiano, que se establecerá que “todo contrato tiene en sí una *conventio*” —acuerdo de voluntades—, por lo que la coincidencia externa de voluntades pasa a la categoría de requisito, tal como lo demuestra el tratamiento romano de los vicios de la voluntad* y lo relacionado con la interpretación de los negocios*.

Poco a poco, pues, se van configurando los requisitos para que se dé un contrato, los cuales podríamos resumirlos del siguiente modo: 1) que haya un *consensus*; 2) destinado a crear obligaciones; 3) que tenga un nombre propio; 4) que esté protegido por una *actio*.

Lo que se dice de la exigencia del nombre propio está referido a la persistencia en el Derecho Romano de que cualquier convención no constituye un contrato; sólo lo constituyen aquellos admitidos jurisdiccionalmente por el pretor —los que tenían un nombre en el edicto al concedérsele una *actio*.

VI. Se conformó también, por razones de equidad, la doctrina de los contratos innominados —que fue iniciada por La-beón a comienzos del Principado, pero concluida mucho tiempo después—, según la cual, una convención que no entrara en los contratos reales o consensuales, siempre que fuera ejecutada por una de las partes, daba a ésta una *actio* especial contra la otra, acción que en los textos justinianeos es denominada *actio praescriptis verbis* (acción con palabras puestas al principio [de la fórmula]).

VII. También en el derecho imperial se admitirá que ciertos pactos —la regla era que “del pacto no nace ninguna acción”— gozarían de protección jurisdiccional, por ejemplo, en los casos de la donación y de la constitución de dote.

VIII. Siempre dentro de las características señaladas, sólo en el Derecho Romano bizantino o en el oriental se dará a la voluntad (*consensus*) un valor más genérico en la fuente contractual, aun cuando sea necesario remarcar que nunca funcionó, tal como ocurre en el derecho moderno, como ejercicio de la “autonomía de la voluntad”. Simplemente tuvo el efecto de destacar que la entrega de la cosa en los contratos reales o la exteriorización escrita en los contratos literales funcionaban como meras formas del consentimiento.

CLASIFICACION

Aparte de los tipos indicados por Gayo —los que se estudiarán más adelante— se han hecho varias distinciones.

(A) Contratos a título oneroso y a título gratuito. — Se entiende que es a título oneroso cuando la ventaja patrimonial obtenida por una parte ocasiona una contraprestación de la otra, como en la compraventa. Es a título gratuito cuando esa contraprestación no existe, como en el depósito.

(B) Contratos unilaterales y bilaterales. — Según que den origen a obligaciones para una sola parte —por ejemplo, el mutuo— o para ambas— por ejemplo, la compraventa.

- Los contratos bilaterales son llamados también sinalmáticos, pudiendo a su vez distinguirse entre sinalmáticos perfectos —cuando *ab initio* nacen obligaciones recíprocas entre las partes, como en la compraventa y la locación— y sinalmáticos imperfectos —cuando *ab initio* sólo nacen obligaciones para una de las partes, pero eventualmente pueden nacer para la otra; es el caso del depósito, en el que las obligaciones son sólo para el depositario, pero éste puede obligar al depositante en ciertos casos, así cuando ha efectuado gastos para la conservación de la cosa.
- En el caso de los contratos bilaterales, una parte no puede exigir el cumplimiento de las prestaciones de la otra antes de haber cumplido u ofrecido cumplir la propia. Sobre la base de este principio —admitido

cf

por equidad— la doctrina moderna construirá la *exceptio non adimpleti contractus* (excepción de contrato no cumplido).

(C) *Contratos de ius civile y contratos de ius gentium.*— Como resulta obvio, los primeros provienen del derecho propio de los ciudadanos romanos y son, en general, los más antiguos; los segundos nacieron de la experiencia del tráfico mediterráneo y fueron admitidos por el pretor peregrino, como la compra-venta, la sociedad, el comodato, el mutuo.

- * La importancia de esta división reside en que los primeros dan origen a *actiones iuris stricti** —en las cuales la labor del juez se reduce a comprobar su existencia o inexistencia, condenando o absolviendo—. Los segundos dan lugar, normalmente, a *actiones bonae fidei**.

Trataremos ahora de las cuatro clases de contratos que indicó Gayo: los verbales, los literales, los consensuales y los reales.

CONTRATOS VERBALES

Los contratos verbales son aquellos que se perfeccionan por el pronunciamiento de palabras solemnes.

STIPULATIO

La *stipulatio* es una promesa oral de realizar una prestación, a instancias de una pregunta, realizada por quien va a resultar acreedor.

- * El requisito fundamental es la *unitas actus* (unidad de acto), de tal modo que las dos partes deben estar presentes, la pregunta y la respuesta deben ser hechas oralmente y debe suceder inmediatamente en el tiempo la una a la otra. Además, la respuesta debe ser congruente con la pregunta. Así, por ejemplo, si se pregunta: "¿Prometes...?", no es válido contestar: "Haré", o contestar poniendo una condición o un plazo que no estaban en la pregunta.

- * Las fórmulas usadas pueden ser variadas. Así, por ejemplo: "¿Darás?"; "Daré". "¿Prometes por tu fe?"; "Prometo por mi fe". "¿Harás?"; "Haré". Incluso las fórmulas podían ser realizadas en griego. En cuanto a las expresiones "*Spondeo*" y "*Spondeo*", configuran la *sponsio*, que se rige por las mismas reglas que la *stipulatio*, pero que está reservada sólo a los ciudadanos romanos —lo que se explica por su origen religioso, que lo semeja, en líneas generales, a una fórmula juramentada, es decir, sometiéndose en caso de incumplimiento a sanciones sacras de la divinidad.

I. La *stipulatio* fue el contrato más usado durante la época clásica. La sencillez de sus formas y la maleabilidad con que puede amoldarse a las circunstancias más variadas, lo hará el preferido para la constitución de los distintos negocios. Incluso puede servir para asegurar formalmente otro tipo de obligación: así, una indemnización de daños que se deba. El pretor utilizará este contrato para crear las estipulaciones pretorianas* y también las múltiples *cautiones* (garantías).

II. Tradicionalmente fue un contrato oral. Pero dentro del período clásico se admitió que fuera acompañado de un documento escrito (*cautio*) que sirviera como elemento probatorio. Más tarde, en el período posclásico, el principio de la oralidad pierde terreno, y bajo la influencia de las costumbres orientales, la *stipulatio* se convierte en un contrato escrito: en el 472 d.C., una constitución del emperador León, si bien permite libertad en cuanto a las palabras usadas, está presuponiendo la forma escrita.

III. De la *stipulatio* nace una acción, la *actio ex stipulatu*, la cual podía ser con *formula certa* —cuando el *quantum* de la obligación aparece claramente expresado— o con *formula incerta* —cuando no es así, o la obligación es de hacer.

Por lo general, la *stipulatio* es un negocio abstracto*; es decir, que funciona sin referencia a la causa* jurídica. En un principio —por ser *actio stricti iuris*—, el juez se imitaba a comprobar su existencia o inexistencia y dictar la sentencia. Con posterioridad, se permitirá al demandado oponer la *exceptio doli* mali*.

- * Sin embargo, las partes podían añadirle la vinculación a una "causa". Así, por ejemplo: "¿Prometes darme los 100 que me debes en virtud de la compra del fundo tusculano?". En este caso, si no existía ninguna

74

504 1

73

obligación nacida de la compra, la acción era rechazada sin necesidad de interposición de una *exceptio*.

- En el derecho posclásico —dada la costumbre de la *stipulatio* escrita— aparecerá cada vez más vinculada con la causa. Las reglas son, en general, las mismas: si en el documento no hay mención de causa, se puede accionar sin probarla; en cambio, si ésta figura, hay que probarla previamente. En el derecho bizantino parece haberse exigido ya la prueba de la causa incluso no habiendo mención de ella en el documento.
- Si el prestamista hizo celebrar la *stipulatio* en su favor y luego no dio el dinero, podía ver detenida su acción, primero por la *exceptio doli* y luego, más concretamente, por la *exceptio non numeratae pecuniae*.

IV. La *stipulatio* puede servir también para la aplicación de la llamada **cláusula penal**. Por ejemplo: “¿Prometes darme al esclavo Sticho? Si no me lo dieras, ¿prometes darme 100?”. Esta cláusula servía para asegurar el cumplimiento, evitando al mismo tiempo al acreedor la prueba —en general difícil— del perjuicio que se sufre.

Adstipulatio. — El *adstipulator* es un acreedor accesorio que goza de la confianza del acreedor principal y del cual éste se sirve para cobrar el crédito.

- La forma es así: cuando se realiza la *stipulatio*, inmediatamente después se hace prometer la misma prestación por parte del deudor: “¿Prometes darme lo mismo?”.
- Servía para dos fines: (a) permitir al acreedor que debiera ausentarse tener una persona de confianza que pudiera demandar en justicia al deudor; (b) permitir la validez de una *stipulatio* con la cláusula “que la cosa sea dada después de nuestra muerte”, ya que de lo contrario sería nula.
- Por ser accesorio, la obligación del *adstipulator* puede ser menor o igual a la del acreedor principal, pero no mayor.
- Si traicionando la confianza depositada el *adstipulator* produce la *acceptilatio* de la deuda, responderá con una multa sancionada en el capítulo II de la *lex Aquilia*.

DOTIS DICTIO

Se trata de una promesa solemne de dote* que podía ser hecha por la mujer misma que iba a contraer matrimonio, o por su *pater*, o un deudor de ella, y estaba dirigida a especificar qué bienes constituían la dote.

NF

- Según parece ser, éste es un contrato *uno loquente* (con sólo uno que habla), es decir que no hay una pregunta y una respuesta, sino la enunciación de una fórmula solemne efectuada por el promitente: “Ticio, la dote que te daré será de 10.000”.
- Se permitirá también efectuar la promesa de dote por medio de una *stipulatio* que será la *promissio dotis*. Las diferencias con la anterior, aparte de la existencia de una pregunta y una respuesta, estaba en la limitación de las personas que podían comprometerse por la *dotis dictio*, mientras que la *promissio dotis* podía ser efectuada por cualquiera.
- Más tarde, por una constitución de Teodosio (año 328) se hizo de la promesa de la dote un pacto legítimo, por lo que cayeron en desuso las formas anteriores.

PROMISSIO IURATA LIBERTI

Consistía en una promesa juramentada por la cual el liberto se comprometía a efectuar determinadas obras en favor de su patrono.

La forma usual era que antes de manumitirlo, el *dominus* le hacía prestar al futuro liberto un juramento obligatorio, al cual era seguido, luego de la manumisión, por un segundo juramento, ya que se pensaba que el primero, prestado cuando aún era esclavo, no tenía completa exigibilidad.

Esta forma de obligarse era también *uno loquente*. Para exigir su cumplimiento el patrono gozaba de una *actio operarum*.

CONTRATOS LITERALES

Los contratos literales son aquellos que se perfeccionan por medio de la escritura.

NOMINA TRANSCRIPTICIA

Se vinculan estos contratos con la costumbre que tenía cada *pater* de llevar el estado patrimonial en dos libros: uno de

ellos era una especie de borrador, llamado *adversaria*, en el cual se llevaba la nómina de todas las entradas y salidas en forma diaria, volcándose luego las anotaciones en forma periódica en un segundo libro, el *codex accepti et expensi* (cuaderno de lo entrado y de lo gastado), que estaba dividido en dos columnas: *tabula accepti* (donde se anotaban las entradas) y *tabula expensi* (donde se anotaban las salidas).

Hasta aquí resultaría que este libro es sólo un medio de prueba de las obligaciones, pero fue empleado además para crearlas. El procedimiento variaba según las dos formas que se solían emplear: *a re in personam* y *a persona in personam*. Ambas son conocidas como *nomina transcripticia*.

- Las dos formas tenían de común lo siguiente: (A) que la anotación debía ser efectuada con consentimiento del deudor en el libro del acreedor, el cual podía darse verbalmente estando presente y (B) debía anotarse la causa de la obligación.
- El *nomen transcriptitium*, conocido como *a re in personam*, servía para lograr los efectos de una novación objetiva. Se realizaba del siguiente modo: supongamos una venta anterior, de la cual se me debe el precio; yo, acreedor, inscribo primero en la página del *acceptum* el monto del precio como si lo hubiera recibido (*acceptilatio ficticia*) y de este modo se extingue la obligación mencionada; pero al mismo tiempo transcribo dicho monto en la página del *expensum* como si hubiera salido de mi patrimonio una suma por dicho valor (*expensilatio ficticia*), y al quedar así anotada, se ha producido el nacimiento de una nueva obligación, no nacida de la compraventa, sino de esta forma escrita. Este procedimiento sirve para renovar una obligación ya existente, o también para convertir en exigible una obligación que no lo es, como ser una obligación natural.
- El *nomen transcriptitium*, conocido como *a persona in personam*, es utilizado para lograr los efectos de una novación subjetiva. Supongamos que Ticio es acreedor de Sempronio por la suma de 100, y a su vez Sempronio es acreedor de Mevio por la misma suma. Para evitar un doble pago de dichas obligaciones, Sempronio va a delegar a su deudor Mevio para que pague los 100 directamente a Ticio. Esto se instrumentaba del siguiente modo: en su libro Ticio anotará en el *acceptum* que ha recibido de Sempronio los 100 (*acceptilatio ficticia*), y para hacer nacer la obligación literal para Mevio anotará en el *expensum* que ha prestado 100 a Mevio (*expensilatio ficticia*). Desde ahora en adelante, Sempronio queda excluido y Mevio queda obligado directamente por 100 hacia Ticio. Una tal delegación se hacía a menudo por intermedio de los hombres de negocio, en particular, banqueros (*argentarii*).
- Posiblemente los *nomina transcripticia* hayan continuado siendo utiliza-

dos durante la época clásica —como se advierte por el tratamiento que les da Cayo— o más aún —utilizados por los banqueros— en la época posclásica. Justiniano no dará acogida a este tipo de contratos.

CHIROGRAPHY Y SYNGRAPHAE

El uso de estos instrumentos provino del derecho griego —de donde precisamente derivan estas voces— y su aplicación inmediata estuvo referida al tráfico comercial de los peregrinos, aprovechándose de ellos también los romanos.

El *chirographum* era un documento firmado solamente por el deudor y sellado con su anillo; aquél quedaba en poder del acreedor. De ahí que se parezca a nuestro moderno “pagaré”.

La *syngrapha* era un documento extendido en dos ejemplares, firmados y sellados ambos, de los cuales quedaba uno en poder del acreedor y otro en poder del deudor.

- Lo que no se sabe con certeza era si servían como meros medios probatorios o si ambos —o al menos las *syngraphae*— tenían un valor abstracto constitutivo de obligaciones. Cayo subraya que se realizaban fuera de toda *stipulatio* previa, lo que los acercaría a nuestros papeles abstractos de comercio; no habría en consecuencia necesidad de hacer figurar una causa preexistente.
- Pero a partir de cierto momento —quizá en la época de Caracalla, en el año 215 d.C.— se permitió la *exceptio non numeratae pecuniae* a fin de que el actor debiera probar la existencia de la causa de la obligación —los motivos debieron estar probablemente en evitar los excesos de la usura—. Esta *exceptio* sólo podía ser opuesta dentro del plazo de cinco años a contar de la redacción del documento, ya que después éste era inatacable en ese aspecto. Este plazo fue reducido por Justiniano a sólo dos años.
- En la práctica, luego de la época clásica, se fusiona con la *stipulatio* documentada.

CONTRATOS CONSENSUALES

Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento (*consensus*), sin ser requisito necesario ninguna formalidad verbal o escrita.

75

504 1

75

- Por este motivo es que pueden ser contraídos incluso entre ausentes, como, por ejemplo, por una carta o por un mensajero; en cambio, en los contratos formales —caso de los verbales— esto es imposible.

COMPRAVENTA

La compraventa (*emptio venditio*) es un contrato por medio del cual una persona llamada vendedor (*venditor*) se obliga a transmitir la posesión de una cosa asegurando su pacífico goce a otra llamada comprador (*emptor*), que se compromete a abonar por ella un precio consistente en una suma de dinero.

- Remarquemos que por la compraventa no se transmite la "propiedad" sino la "posesión", y por ello la prestación del vendedor no sería, típicamente un *dare*, sino un *praestare*; en cambio, si sería un *dare* la del comprador, que debe transferir el dominio del dinero del precio.
- Para adquirir el comprador el dominio de la cosa se hace necesaria la *traditio* de la cosa, respecto de la cual la compraventa funciona como *iusta causa*.
- En la época posclásica, bajo la influencia del derecho oriental, comenzó a utilizarse la documentación escrita. Así, Constantino exigirá para la compraventa de inmuebles el documento escrito —aparte de hacer constar el pago de los impuestos, propósito principal de esta legislación—. Justiniano permite, a elección de las partes, que se formalice por escrito o no. Y si bien continúa encasillándolo entre los contratos consensuales, determinará que si las partes optaron por la forma escrita, el contrato no se perfecciona hasta la suscripción del mismo.
- La compraventa, institución del *ius gentium*, con su consecuente *traditio*, reemplazó en el desarrollo histórico a la ritual *mancipatio*, propia del *ius civile*.

I. Respecto del consentimiento, rige en Roma el principio de que nadie puede ser obligado a vender una cosa contra su voluntad. Desde la época clásica se acostumbró, también, a utilizar el instituto de las arras.

- Sólo en casos muy excepcionales puede haber obligación de vender una cosa. Así, por ejemplo, en virtud de una constitución de Antonio Pío respecto del esclavo maltratado por su dueño, o respecto de cereales, cuando una grave calamidad azotaba a Roma. Con excepción de

estos casos, regía el principio del consentimiento libremente expresado y sin vicios que lo aquejaren.

- Las arras consisten en la entrega de un objeto o de una suma de dinero. En la época clásica, el comprador solía entregar al vendedor, para dar firmeza al contrato, ya un anillo, ya una cantidad de dinero. Cumplidos la entrega de la cosa y el pago del precio, el vendedor devolvía el anillo, y si había recibido una suma de dinero, ésta era imputada al precio de la compra. Son, pues, arras confirmatorias.
- En la época de Justiniano tuvieron carácter de arras penales para asegurar la posterior redacción por escrito. Se permitía el arrepentimiento, pero con pérdida de las arras si se trataba del comprador y con la devolución de ellas más otro tanto similar a su valor si se trataba del vendedor.
- Más discutidas eran las arras penitenciales, debido a la obscuridad del texto justiniano. Parecería que, incluso, una vez perfecto el contrato oral o escrito, las partes, por entrega de arras, podían incluso desistir del negocio. El dinero de ellas servía como expiatorio y de ahí el nombre de penitenciales.

II. Respecto del objeto de la compraventa, ésta podía versar tanto sobre *res corporales* como sobre *res incorporales*. Por ejemplo, una servidumbre, siempre y cuando estuviera *in commercio*, es decir, que pudiera ser negociada.

- Podía incluso versar sobre una cosa futura. Los romanos admitían dos supuestos: la *emptio spei* (compra de la esperanza), que podríamos ejemplificarla con el siguiente caso: "Te compro lo que pesques echando la red", por lo que se entendía que sacando diez peces o ninguno, lo mismo se debía el precio, y la *emptio rei speratae* (compra de la cosa esperada): "Te compro la próxima cosecha", entendiéndose que si ésta se perdía, la venta no quedaba perfeccionada; es decir, era condicional.
- Estaba también permitida la venta de cosas ajenas. Se entendía en este caso que el vendedor se comprometía a obtenerlas de la otra persona, y si no lo lograba, debía responder ante el comprador por los daños.

III. Respecto del precio de la compraventa, debe tener los siguientes caracteres: (A) debe ser en dinero; (B) debe ser cierto; (C) debe ser verdadero. En la última época, se agregará (D), que debe ser *iustum* (justo).

(A) Respecto a que debía consistir en dinero, hubo una controversia entre las escuelas. Los proculeyanos opinaban que debía ser necesariamente *in pecunia numerata* (dinero contante); los sabinianos, en cambio, admitían que podía ser en otras

2f

cosas, como un esclavo, una toga o un fundo del otro contratante. Justiniano dará la razón a la primera de las escuelas.

- * Esta discusión pudo estar motivada por el propósito de los sabinianos de incluir la permuta (*permutatio*) dentro del régimen de los contratos, que estaban protegidos por acciones, ya que aquella figuraba como mera convención no protegida. Más tarde entrará en la categoría de los "contratos innominados". Así y todo, estos contratos son considerados reales, pues se perfeccionan con la *datio* y por lo tanto quedarían diferenciados de la compraventa, que se perfecciona por el *consensus*.

(B) La certidumbre del precio radica en la determinación o posibilidad de determinación exacta del monto del precio.

- * El precio puede ser determinado —por ejemplo, 100 ases— o determinable: "Te la compro por cuanto tú la compraste", o "Te la compro por cuanto tenga en este momento en mi arca".
- * Pero ya en la época clásica se plantearon muchas dudas acerca de la validez de una venta resumida en la expresión "Te la compro por el precio que estime Ticio que vale". Justiniano la admitirá, entendiendo que se está en presencia de una condición, de tal modo que si el tercero designa el precio, la venta queda concluida; de lo contrario, no hay venta.

(C) El precio debe a su vez ser verdadero (*verum*), en el sentido de que no sea simulado, porque de lo contrario habría una donación. Esto fue precisamente hecho, a veces, para eludir las normas prohibitivas de ciertas donaciones*.

(D) Finalmente, en la época posclásica se estableció que el precio debía ser justo por los inconvenientes de la devaluación de la moneda y debido al influjo moral de la teología cristiana. Entendiéndose que cada cosa tiene su justo precio, Justiniano estableció la rescisión del negocio en caso de lesión enorme (*laesio enormis*), la cual ocurría cuando el precio era inferior a la mitad del justo valor de la cosa.

IV. De la compraventa emanan las siguientes acciones.

(A) La *actio empti*, que puede ejercerla el comprador contra el vendedor. Su propósito es lograr la posesión de la cosa vendida.

- * Debe destacarse que el vendedor no está obligado, en principio, a transferir el dominio de la cosa, sino simplemente la posesión de la misma libre de toda injerencia de terceros, es decir, la *vacua possessio*.

- * El vendedor responde en caso de no poder entregar la cosa por haberse destruido, sea por su dolo o por su culpa. Solamente quedaría liberado por caso fortuito* o fuerza mayor*.

(B) La *actio venditi*, que puede ejercerla el vendedor contra el comprador. Su propósito es exigir el pago del precio de la cosa vendida y, eventualmente, el pago de intereses u otros accesorios.

- * El comprador debe el precio aunque la cosa se haya destruido por caso fortuito o fuerza mayor antes de la entrega. Significa esto que los riesgos de la cosa son a cargo del comprador, ya que por ser consensual, el contrato quedó perfeccionado desde el momento mismo del consentimiento. Las únicas excepciones son el dolo o la culpa del vendedor, pues se entiende que éste tiene el deber de custodia de la cosa.
- * También puede exigirse al comprador el pago de los gastos necesarios realizados para la conservación de la cosa vendida.

V. Por ser un contrato de buena fe, como elementos naturales* —es decir implícitos— de la compraventa aparecen (A) la evicción (garantía de los vicios jurídicos) y (B) los vicios redhibitorios (garantía de los vicios materiales).

(A) Según hemos visto, el vendedor no está obligado a transmitir al comprador la propiedad de la cosa. Basta que le entregue la posesión de la cosa libre de ocupantes y le asegure esa pacífica posesión. Esta situación se puede ver alterada cuando un tercero iniciare la "acción reivindicatoria" alegando que la cosa es en realidad suya.

1) En el viejo derecho —habiéndose realizado la *mancipatio**— el comprador puede reclamar que el vendedor y garante (*auctor*) comparezca en el juicio, a los efectos de defenderlo. Si rehúsa hacerlo o si su intervención es infructuosa, porque el juicio se pierde, la ley de las XII tablas le concedía al comprador la *actio auctoritatis** contra el vendedor por el monto del doble del precio pagado.

2) En la evolución posterior, la evicción es elemento natural de la compraventa siempre que haya mediado la *mancipatio*. Si ésta no tuvo lugar, era necesario que se previera la situación por medio de una *stipulatio* por el doble del valor (*stipulatio duplae*).

76

504 1

75

- En ambos casos se sigue usando la garantía por el *duplum* para el supuesto de que citado el vendedor, se perdiera el juicio de reivindicación llevado a cabo por un tercero.
- Surgió también la posibilidad de que el comprador pudiera obligar al vendedor a celebrar la *stipulatio duplae*.
- Igualmente se podía actuar por la *actio empti* si el bien comprado estaba gravado con una servidumbre no denunciada. En ese caso, se podía reclamar el importe del interés perjudicado.

3) Finalmente, en la época justiniana, suprimida la *mancipatio*, se entendió que la evicción tenía lugar, siempre por el *duplum*, hubiera o no habido estipulación especial.

(B) Respecto de los vicios redhibitorios, en principio, el vendedor responde ante el comprador por los vicios que tenga la cosa y que él hubiera silenciado de manera dolosa; por ejemplo, si aseguró la existencia de ciertas cualidades esenciales que luego la cosa no tuvo.

1) Pero ocurre que esto no basta, por cuanto la cosa vendida puede adolecer de ciertos vicios ocultos, entendiéndose que el vendedor pudo no estar anoticiado de ello y por tanto no existir dolo. Para prevenirlos se utilizaba la garantía de una *stipulatio*, comprometiéndose el vendedor a responder por ellos.

2) Esta cuestión de los vicios ocultos va a ser objeto de especial tratamiento por parte de los ediles curules —que tenían bajo su cuidado los mercados—, quienes en su edicto, a propósito de los negocios que versaban sobre esclavos y animales de tiro y carga, van a establecer, como elemento implícito en las compraventas, la responsabilidad del comprador por los vicios ocultos denominados también redhibitorios.

3) Se otorgaban dos acciones, a elección del comprador.

a) La *actio redhibitoria*, cuyo objetivo era lograr la resolución del negocio, de tal modo que se devolviera el precio pagado contra la entrega del objeto comprado. Sólo se podía ejercitar dentro de los seis meses siguientes al negocio.

b) La *actio quanti minoris*, cuyo objetivo era, dado que el comprador deseaba retener la cosa viciada, lograr una aminoración del precio pagado. Se podía ejercitar dentro del año.

4) Finalmente, Justiniano extenderá estas acciones a toda clase de compraventa.

VI. A la compraventa se le suelen agregar ciertos pactos —*pacta adiecta*— tendientes a modificar los efectos normales del contrato. Los más importantes son los siguientes.

(A) La *lex commissoria*. Se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a una condición resolutoria: que el comprador pague el precio dentro de un plazo determinado. Si así no ocurriere, deberá restituirse la cosa con los frutos percibidos.

(B) El *pactum displicentiae*. Se celebra el negocio, pero se lo deja subordinado a la condición resolutoria de que, si la cosa no resulta del agrado del comprador dentro de un plazo determinado, entonces deja de haber negocio. También podía ser establecida como condición suspensiva, de tal modo que el negocio sólo se perfeccionaba cuando el comprador manifestaba su interés en un plazo dado.

- Si no se había fijado un plazo, el pretor concedía una *actio in factum*, que debía ejercitarse dentro de los 60 días para declarar sin vigor el contrato. Si transcurrido dicho plazo no se ejercitaba la *actio in factum*, la venta quedaba firme —caso de la condición resolutoria—; si se la ejercitaba, se la tenía por no concluida —caso de la condición suspensiva.

(C) *In diem addictio*. El vendedor se reserva el derecho de rescindir la compraventa si dentro de un plazo determinado aparece un interesado que le ofrezca un mejor precio.

(D) El *pactum de retrovendo* (pacto de retroventa). Por medio de él el vendedor se reserva la facultad de readquirir la cosa dentro de un cierto plazo, mediante la restitución del precio pagado.

- Este pacto resultó siempre sospechoso por ocultar generalmente operaciones usurarias, como cuando el prestamista se hace vender la cosa por un precio omnicompreensivo del capital e intereses, y que de no efectuarse el pago se queda directamente con la propiedad de la cosa.

(E) El *pactum de retroemendo*. Es el pacto por medio del cual el comprador puede obligar al vendedor a que le readquiera la cosa vendida, luego de transcurrido un plazo, por el mismo precio.

OF

LOCACION

La locación (*locatio conductio*) es un contrato por medio del cual una persona, locador (*locator*), se obliga a entregar a otra llamada locatario (*conductor*) el uso o el uso y el disfrute de una cosa determinada, o la prestación de ciertos servicios, mediante el pago de un precio denominado generalmente alquiler (*merces*).

- Los romanos entendieron este contrato consensual desde un punto de vista unitario. La división que se suele hacer entre *locatio conductio rei* (locación de cosas), *locatio conductio operarum* (locación de servicios) y *locatio conductio operis* (locación de obra) no es estrictamente romana, sino que corresponde a los autores modernos, posiblemente a los del s. XVII.
- La denominación romana es bastante expresiva. *Locator* hace referencia a quien "coloca algo", se trate de una cosa o del trabajo de la propia persona. Recíprocamente, *conductor* es aquel que "lleva consigo" la cosa o la persona que prestará los servicios.

I. En la locación de cosas el locador se compromete a entregar a la otra parte la cosa locada, corriendo a su cargo las reparaciones que sea necesario hacer en la misma para un uso adecuado.

II. El locatario se compromete a pagar el precio convenido, debiendo usar de la cosa conforme con el destino de la misma y devolverla una vez concluido el arriendo.

La situación del locatario resulta, frente a terceros, bastante precaria, ya que no es considerado un poseedor, sino un mero tenedor de la cosa, por lo que carece de los interdictos*.

III. Este contrato dura aquello que hayan convenido las partes. De no haberse convenido un plazo, puede darse por concluido por decisión unilateral de cualquiera de las partes en cualquier momento. Se permite asimismo que una vez concluido el plazo, si el locador permite que el locatario continúe con el

uso de la cosa locada, se entienda que el contrato ha sido tácitamente prorrogado (*relocatio tacita*).

- En el derecho posclásico, mientras que el contrato de locación de cosas inmuebles se mantuvo en Oriente, en Occidente fue más bien desplazado por la *enfiteusis*, derecho real que otorgaba mejores ventajas al otorgado arrendatario.

IV. Distingamos entre la locación de servicios y la locación de obra.

En la *locatio conductio operarum*, lo que las partes han tenido en cuenta es la prestación de la *opera*, es decir, la actividad, el obrar del *locator*, que se calcula en espacios regulares de tiempo: se contrata a un albañil para la construcción de un muro, a tanto por día.

En la *locatio conductio operis* se contrata en función de la prestación del *opus*, es decir la obra, el resultado del trabajo del locador, con prescindencia del tiempo que insuma su realización: se le encarga a un albañil la construcción de un muro determinado y se le paga tanto por la realización de ese muro o se le paga por la construcción de cada metro cuadrado de muro. Es decir, se le paga por los resultados —todo el muro o partes de él— y no por la prestación —medida en tiempo— de su actividad.

V. En cuanto a la *locatio conductio* como locación de servicios, la misma no tuvo la relevancia que tendrá después en el derecho moderno. El *locator* —quien presta los servicios— podrá reclamar el pago del salario (*merces*); si por causas atribuidas a él no los presta, nada puede reclamar. El *conductor* debe pagar el salario, incluso si los servicios no se han podido ejecutar por causas imputables a él.

- La poca importancia que tuvo este contrato en Roma se debió en mucho a la existencia de mano de obra esclava, que cubría las necesidades normales.
- Incluso, si bien el empleo de trabajadores libres existió en cantidad no despreciable, cabe tener en cuenta que para ciertos servicios calificados, tales como el de un abogado, médico o agrimensor, resultó sumamente chocante durante mucho tiempo la idea de una retribución obligatoria.
- Será la costumbre, nacida del deber moral del cliente, la que irá tor-

77

504 1

34

nando normal el corresponder a los servicios con un donativo especial (*honorarium*), el cual, al fin de la época clásica, se torna obligatorio y puede demandarse, no por el proceso ordinario, sino por el *extra ordinem*.

VI. En lo que se refiere a la *locatio conductio* entendida como locación de obra, no mereció para los romanos una distinción doctrinaria específica.

- Es presupuesto que la obra sea realizada con materiales del locatario, quien a la postre se quedará con la misma; de lo contrario el contrato sería juzgado como compraventa. Así, hay diferencia entre que le diga a un joyero: "Toma este oro y hazme un brazalete" (*locatio conductio*) o que le diga: "Hazme con tu oro un brazalete"; lo cual sería una compraventa.
- No obstante algunas dudas que pudieron originarse, se entendió que el riesgo (*periculum*) de la cosa corría a cargo del locador hasta tanto se entregase la obra o ésta fuese aprobada, salvo el supuesto de fuerza mayor.

VII. De la locación surgen dos acciones: la *actio locati*—del locador respecto del locatario— y su inversa, la *actio conducti*. Ambas son *bonae fidei*.

- Asimilado a los casos normales de la locación estaba el supuesto de la *lex Rhodia de iactu*, que regulaba el caso del capitán de un navío que debía sacrificar parte de la carga para salvar la nave. Siguiendo la costumbre impuesta por la isla de Rodas, esta ley estableció que las pérdidas debían ser soportadas proporcionalmente entre todos los propietarios. De este modo, en virtud de la *locatio operis faciendi* (locación de obra [entre el dueño del navío y los propietarios de las mercancías], el dueño de una mercadería echada al mar tenía la *actio locati* contra el dueño del navío, quien a su vez gozaba de la *actio conducti* contra los demás dueños de las mercaderías transportadas en su nave para obligarlos a contribuir en la pérdida.

SOCIEDAD

La sociedad (*societas*) es un contrato en virtud del cual dos o más personas (*socii* *) se obligan a hacer aportes en común de bienes o de trabajo para obtener una utilidad común que se repartirán.

- La sociedad se constituye por el libre consentimiento de sus miembros, que lo hacen sobre una base de confianza recíproca (*affectus societatis*); por ello, bastaba que uno solo de los socios decidiera retirarse para que el contrato quedara concluido.
- La sociedad romana sólo genera efectos entre los socios dado que carece de personería jurídica exterior.

I. Había dos figuras de sociedad: la *societas omnium bonorum*, que se caracterizaba por el hecho de que en ella los socios aportaban en común la totalidad de sus patrimonios—tanto los bienes que tenían en el momento de formar la sociedad como los que pudieran adquirirse luego— y la *societas alicuius negotii*, en la cual los aportes se realizaban para una sola operación o una serie determinada de negocios, como, por ejemplo, para comprar y vender esclavos.

- La primera clase de "sociedad" reconoce como su antecedente remoto la comunidad hereditaria, surgida entre los *fili familias* a la muerte del *pater* en la época arcaica, que recibía el nombre de *erctum non citum* *. Esa comunidad doméstica podía ser, también, según Cayo, creada artificialmente por una acción especial. Por Ulpiano también sabemos algo acerca de la *societas omnium bonorum*, quien nos dice que en ella las relaciones entre los socios eran tan estrechas como las que pueden existir entre hermanos.
- La otra clase de sociedad fue de origen posterior y nació por las necesidades del tráfico mercantil. Una variedad distinta se podría ver en la *societas unius rei*, en la que resalta no el ejercicio del negocio, sino el aporte de bienes singulares para un beneficio común, siendo un buen ejemplo el dado por Celso: dos personas, una que posee tres caballos y otra uno, se unen para trabajarlos en común.
- Lo normal es que el aporte se realice con capitales, pero también estará permitido el aporte consistente en el trabajo de uno de los socios. Esto motivó alguna duda en la época clásica, pero lo permitió expresamente una constitución de Dioclesiano.

II. Respecto de las ganancias y de las pérdidas, si nada se convino se entiende que son siempre por partes iguales—pero no en proporción a los aportes—. Si se conviene cómo será el reparto de ambas, el derecho clásico, por regla general, permitirá una relativa desigualdad entre ambas.

- El que uno de los socios pueda tener una proporción mayor en los beneficios que en las pérdidas fue rechazado como contrario a la naturaleza de la sociedad por Q. Mucio Scaevola; pero prevaleció su aceptación tal como la propuso Servio Sulpicio.

FF

- Si se determinaron las proporciones de las ganancias, pero no las de las pérdidas, o viceversa, se debe entender que lo establecido para un caso debe regir para el otro.
- Lo que no admitieron los romanos es la llamada *societas leonina* —llamada así por la conocida fábula de Fedro, donde la vaca, la cabra, la oveja y el león hicieron una sociedad en la cual este último llevaba toda la ganancia—, que sucedía cuando se convenía, por ejemplo, que un socio participara de las ganancias, pero no de las pérdidas.

III. Una vez extinguida la sociedad —por la voluntad de todos, o la de uno solo, o la muerte de un socio, o haber concluido el plazo convenido, o haberse realizado el negocio propuesto—, cada uno de los socios tiene la *actio pro socio*.

- Esta es una *actio bonae fidei* en la cual el socio reclama la rendición de cuentas, la liquidación y el saldo resultante de la compensación realizada entre ganancias y pérdidas. Eventualmente puede también responsabilizar a otro socio por dolo o culpa en el ejercicio de las relaciones societarias. En este caso tiene un carácter infamante.
- En la época de Justiniano se permite también el ejercicio de la *actio pro socio* mientras dure la sociedad, para reclamar la integración de un aporte o las indemnizaciones que son debidas.
- Si hay bienes para repartir, no se actúa por la *actio pro socio*, sino por la *actio communi dividundo*.

MANDATO

El mandato (*mandatum*) es el contrato en virtud del cual una persona —mandante— encarga a otra —mandatario— y ésta acepta realizar algo en favor de aquél.

- Es un contrato consensual, pero bilateral imperfecto, ya que genera, en principio, obligaciones sólo para el mandatario. El consentimiento puede ser expreso —por ejemplo, por medio de palabras o por escrito—, pero también tácito, como sucede en el caso en que estando uno presente, permite que otro maneje sus negocios. En cambio, si no hay consentimiento, puede dar lugar a la gestión de negocios.
- Debe el mandatario encargarse de llevar a cabo la administración de todo un patrimonio —mandato general— o de un negocio determinado —mandato especial.
- El objeto encargado puede ser un simple hecho, o un acto, o un negocio jurídico, siempre que sea lícito y no contrario a las costumbres.
- El mandato debe ser siempre en interés del propio mandante o de un

- tercero. Justiniano, muy cuidadosamente, nos presenta cinco casos: (A) en el solo interés del mandante: verbigracia, si te mando comprar un campo; (B) en interés del mandante y del mandatario: verbigracia, si te mando pedir dinero para invertirlo en una sociedad contigo; (C) en interés de un tercero: verbigracia, si te mando comprar una casa para Ticio; (D) en interés del mandante y de otro: verbigracia, si te mando desempeñar negocios comunes entre yo y Ticio y (E) en interés del mandatario y de un tercero: verbigracia, si te mando prestarle dinero a interés a Ticio.
- Lo que no sería posible es un mandato en el solo interés del mandatario: por ejemplo, si te digo que no tengas el dinero ocioso en tu casa, sino que lo prestes a interés. Esto vale como simple consejo.

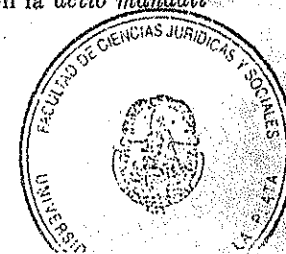
I. El mandatario está obligado a llevar a feliz cumplimiento el encargo del mandante, respetando las instrucciones recibidas o las que rigen en general de acuerdo con la naturaleza del negocio. Él actúa en nombre propio y en interés del mandante, sufriendo éste los efectos de lo actuado como si lo hubiese realizado él mismo.

- Si el mandatario se excedía en los límites de las instrucciones —como, por ejemplo, si se le ordenaba comprar un bien por 100 y lo compraba por 150—, los sabinianos juzgaban que por ese negocio no podía obligar al mandante; en cambio los proculeyanos, cuya solución admitió Justiniano, decían que el negocio podía ser ratificado por el mandante si el mandatario tomaba a su cargo la diferencia.
- Ninguna duda se plantea en el ejemplo anterior si la compra del bien se hubiese hecho por un precio menor al encomendado.

II. El mandato concluye: (A) ya por haberse realizado el negocio encomendado; (B) ya por muerte de alguna de las partes —dada la relación de confianza—; (C) por la voluntad concordada de las partes y (D) también por la voluntad de una de ellas, pudiendo darse el caso de la revocación (*revocatio*) por parte del mandante o el de la renuncia (*renuntiatio*) por parte del mandatario.

- En el caso de la *revocatio*, ésta sólo produce efectos desde el momento en que la conoce el mandatario.
- En el caso de la *renuntiatio*, el mandatario responde de los perjuicios ocasionados en caso de producirse ésta en forma intempestiva.
- En el caso de muerte del mandante, el mandatario puede accionar contra los herederos del mandante si actuó ignorando su muerte.

III. Las acciones nacidas del mandato son la *actio mandati directa* y la *actio mandati contraria*.



70 504 1

77

(A) La primera la tiene el mandante para instar al cumplimiento del mandato, exigiendo todo aquello que hubiese recibido el mandatario con motivo del encargo.

- Responde igualmente el mandatario por el dolo e incluso por la negligencia grave, aun cuando se admitía en algunos casos, también, la responsabilidad por la mera culpa.

(B) La segunda corresponde, eventualmente, al mandatario contra el mandante para reclamar que se le abonen los gastos realizados en el cumplimiento del mandato o los perjuicios ocasionados durante el cometido.

- El mandato es gratuito. Sin embargo, durante el Imperio —aunque manteniendo el principio de la gratuidad— se permitió que si se hubieran convenido honorarios, el mandatario los podía reclamar por la *extra ordinem cognitio*.

CONTRATOS REALES

Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa (*res*).

MUTUO

El mutuo (*mutuum*) es el contrato en virtud del cual una persona —mutuante— entrega a otra —mutuario— una determinada cantidad de cosas fungibles, obligándose éste a devolver otro tanto del mismo género y calidad.

- La forma normal de este préstamo de consumo es por la entrega de dinero y en menor cantidad de casos por entrega de cosas fungibles.
- Por ser un contrato real, la promesa de conceder en fecha futura un préstamo (*pactum de mutuo dando*) es un precontrato y, como tal, carece de acción.
- A veces no era necesaria la *datio* (entrega en propiedad de la cosa), permitiéndose que si una persona, por otra causa, tenía una suma de dinero de otra, y ésta lo autorizaba a retenerla y gastarla, era como si hubiese mediado un mutuo.
- Lo mismo podía ocurrir en el supuesto del *contractus mohatrae*: alguien

quiere obtener un préstamo; el acreedor no le da dinero, sino una cosa para que la venda y retenga el precio conseguido a título de mutuo.

I. Los intereses (*usurae*) no son debidos salvo que haya mediado una *stipulatio* que contemple su exigibilidad.

II. El mutuante tiene, para reclamar la devolución de lo prestado, la *actio certae pecuniae*, si se trata de una suma de dinero; o la *condictio certae rei*, si se trata de otras cosas fungibles.

III. Este contrato de mutuo estaba prohibido para que por él se prestara dinero a un *filiifamilias*. Así lo determinó el senadoconsulto Macedoniano de la época de Vespasiano (siglo I d.C.).

- El motivo y la denominación provienen de que un hijo de familia llamado Macedo, debido al acoso de sus acreedores para conseguir el dinero de la herencia, dio muerte a su padre.
- En virtud de este senadoconsulto el pretor denegaba la acción o concedía la *exceptio senatusconsulti Macedoniani* al demandado.
- Si no obstante esto se pagaba la obligación, no se podía repetir lo pagado, considerándose a esta obligación una *naturalis obligatio*.

IV. Un negocio análogo al mutuo era el *foenus nauticum* o *pecunia traiectica*. Siguiendo costumbres del tráfico marítimo griego, una persona prestaba dinero al armador de una nave, quien lo utilizaba comprando mercaderías. Si éstas se perdían, el riesgo corría para el prestamista, quedando el prestatario libre de obligación. Como compensación por el riesgo que corría se podía admitir un pacto de intereses, los que en la época de Justiniano eran hasta el tope máximo de 12 por ciento anual.

COMODATO

Se llama comodato (*commodatum*) al contrato en virtud del cual una persona —comodante— entrega a otra —comodatario— una cosa para que la use en forma gratuita, debiendo devolverla luego de cumplido el plazo convenido, y si no lo hay, al primer requerimiento de la contraparte.

- * Se trata acá de un préstamo de uso. A diferencia del mutuo, el comodante no adquiere la propiedad ni tampoco la posesión —no tiene los interdictos posesorios—, sino la mera tenencia de la cosa.
- * Pueden ser objeto de este contrato las cosas muebles o inmuebles, debiendo en principio ser no consumibles. Se admite, sin embargo, que pueda versar sobre una cosa consumible —por ejemplo, una botella de vino— si lo único que se pretende es ostentarla (*ad pompam vel ostentationem*).

I. El comodatario debe usar la cosa de un modo normal o teniendo en cuenta lo convenido. Responde de la custodia de la cosa, bastando la mera culpa de parte suya. Si hace un uso distinto al convenido, puede caer en el *furtum usus* *.

II. Del comodato nace para el comodante la *actio comodati* a los efectos de recobrar la cosa prestada.

- * Primero se la admitió como *formula in factum*, pudiendo el demandado ser condenado por el valor de la cosa y lo que ésta hubiera obtenido. Luego, en la época clásica, se la admitió *in ius concepta*, pudiendo reclamarse la indemnización de todo daño producido.

III. El comodatario gozaba del *contrarium commodati iudicium*, por medio del cual podía reclamar del comodante el pago de gastos realizados por él para mantener la cosa, así como perjuicios sufridos por haberse entregado una cosa defectuosa.

DEPOSITO

Se llama depósito (*depositum*) el contrato en virtud del cual una persona —depositante— entrega a otra —depositario— una cosa mueble para que la guarde, obligándose éste a devolverla cuando aquél la reclame.

- * El depositario es un mero tenedor de la cosa. No puede usarla —cometería *furtum usus*—; debiendo custodiaria hasta que se la reclame el depositante; o si medió un plazo, al vencer éste.
- * Dado el carácter del depósito, el depositario responde sólo por dolo, aunque en el derecho posterior se admitió también la responsabilidad por culpa lata *.
- * En principio es un contrato gratuito, aunque en la época justinianea se permitió la retribución de una pequeña suma.

I. Hay varias figuras de depósito.

(A) Depósito regular. — Es en realidad el que hemos descripto arriba.

(B) Depósito irregular. — En la época posclásica se admitió el depósito del dinero u otros objetos fungibles, facultándose al depositario para consumirlos y devolver otro tanto.

- * En la época clásica va a ser juzgado como un mutuo, pero luego se hará una diferencia, por cuanto acá se da en interés del depositante. Es el antecedente de los depósitos bancarios.

(C) Depósito necesario o miserable. — Es el que tiene lugar cuando en casos de tumulto, incendio, ruina, naufragio, el depositante no tiene mayores opciones para elegir el depositario.

- * Se lo juzga más severamente. Si existe dolo por el depositario, deberá responder por el doble. Puede llevarse a cabo contra sus herederos, quienes si cometieron también dolo responden por el doble del valor de la cosa; si sólo hubo dolo del causante, por el valor simple.

(D) Secuestro. — Es el que sucede cuando se entrega la cosa litigiosa a una de las partes o a un tercero. Debe, por supuesto, devolverla una vez dilucidada la cuestión judicial.

A diferencia del depósito común, el secuestratario tiene a su favor la protección de los interdictos en caso de que alguien lo perturbe o le arrebathe la cosa.

II. El depositante tiene la *actio depositi* para la restitución de la cosa, la cual tiene carácter infamante.

El depositario tiene un *contrarium depositi iudicium* para obtener lo que pagó para mantener la cosa y eventualmente por los daños sufridos.

PRENDA

Se llama prenda (*pignus*) el contrato en virtud del cual un deudor, como garantía del pago de la obligación, entrega al acreedor la posesión de una cosa.

79

504 1

78

La palabra *pignus* sirve para designar: (A) este contrato real; (B) la cosa misma dada en prenda; (C) el derecho real que el acreedor tiene sobre la cosa dada en prenda.

- Dada la vinculación que tiene este contrato con la garantía real de la prenda, estudiaremos allí la relación con el mismo.
- Digamos simplemente acá que de pagarse la deuda, el deudor tenía la *actio pignoratitia* para recobrar la cosa prendada. Si no se pagaba, dependía de la existencia en este contrato del *pactum commissorium*, en el que el acreedor queda como propietario de la cosa. O del *pactum vendendi*, en el que el acreedor no se puede quedar con la cosa; debe subastarla y devolver el *superfluum* —lo que sobrara una vez satisfecho el monto de la deuda— al deudor. Este *superfluum* puede ser demandado por la *actio pignoratitia*.

CONTRATOS INNOMINADOS

I. El sistema contractual —formado por el sistema cerrado de figuras de los contratos nominados, únicos protegidos con acciones— reveló algunas insuficiencias debido a la existencia de ciertas convenciones que no entraban dentro de la caracterización típica ya formulada.

- Estas situaciones eran del tipo “te doy alguna cosa para que me des otra”, o “te doy alguna cosa para que me hagas algo”, las cuales no entraban ni en el concepto de la compraventa ni en el de la locación, en las que el precio debía ser en dinero.

II. Como en estos casos existían regularmente una prestación y una contraprestación, no había inconvenientes si ambas partes las ejecutaban. Pero si una de ellas había transferido una cosa y no obtenía la contraprestación, se le admitía la posibilidad de interponer la *condictio ob rem dati re non secuta* —o también *condictio causa data causa non secuta*— para que pudiera repetir lo pagado, es decir, pedir la devolución.

- Este remedio podía utilizarse en el supuesto de que se hubiera entregado una cosa, pero resultaba inútil si la prestación había consistido en un *facere* (hacer) que, como es obvio, no se puede repetir.
- Para solucionar esto, en ciertos supuestos se concedió la *actio doli* para aquel que, fraudulentamente, hubiera promovido la realización de un hecho sin efectuar la contraprestación.

III. En una época posterior, y atribuido al jurista de origen griego Aristón, de la época de Trajano, a fines del siglo I o comienzos del siglo II d.C., se admitió que en ciertas figuras, quien ya había efectuado una prestación, podía exigir a la otra parte el cumplimiento de la contraprestación mediante una *actio in factum*.

IV. Será la escuela romano-bizantina la que terminará de estructurar estas figuras mediante la concesión de una acción genérica denominada *actio praescriptis verbis*.

- La denominación de esta *actio* se debe a la colocación de palabras (*verba*) puestas al comienzo de la fórmula —*praescriptio*—.
- Estos contratos se consideran siempre “contratos reales” porque en ellos la prestación debía preceder siempre a la contraprestación reclamada.

V. Los juristas, partiendo de un texto de Paulo, bastante transformado por ellos, construyeron las cuatro figuras genéricas siguientes:

“ <i>do ut des</i> ”	(“doy para que des”)
“ <i>do ut facias</i> ”	(“doy para que hagas”)
“ <i>facio ut des</i> ”	(“hago para que des”)
“ <i>facio ut facias</i> ”	(“hago para que hagas”)

De este modo, siempre que mediara la precedente prestación, la parte que la hubiere realizado podía, a su elección: (A) repetir el objeto transferido mediante la *condictio ob rem dati* o (B) demandar el cumplimiento de la prestación contraria mediante la *actio praescriptis verbis*.

VI. Entre los principales contratos innominados podemos señalar los siguientes.

PERMUTATIO

En virtud de ella, una de las partes entrega a la otra la propiedad de una cosa a cambio de una prestación similar de la parte contraria. Es, pues, del género *do ut des*.

- Nótese que a diferencia de la compraventa, donde el vendedor se obliga

PF

a transmitir la posesión pacífica, aquí lo que se transmiten ambas partes es el dominio de los respectivos objetos.

AESTIMATUM

Consiste en que una persona entregue a otra una cosa estimada en un valor determinado. Esta la puede vender, incluso a un precio superior. Si luego de un cierto tiempo no la vendió, deberá devolverla. En cambio, si la vendió, lo único que podrá requerir el primero será el valor estimado, quedándose el otro con la diferencia entre este valor y el de la compraventa que realizó.

- * Como se ve, es algo así como una venta a consignación. Se discutió si aquí había una compraventa, una locación de servicios o una locación de obra. El pretor, en la primera época, se limitó a otorgar un *actio in factum*.

PRECARIUM

Es la entrega gratuita de una cosa a otro para su uso, pudiendo el primero reclamarla cuando le plazca.

LA DONACION CON CARGO

Ocurre cuando alguien dona una cosa, imponiendo al beneficiado un cargo o modo a favor de él o de un tercero.

TRANSACTIO *

Es acuerdo de partes para poder, mediante concesiones recíprocas, poner fin a un litigio o evitarlo.

PACTOS

I. La palabra pacto (*pactum*) ha tenido varios sentidos de acuerdo con su evolución histórica.

Primitivamente la idea de pacto sirvió para designar toda remisión o aplazamiento de una obligación, fuera respecto de la

nacida de una fuente contractual, fuera de la nacida de un delito.

- * La palabra *pactum* deriva de *pax* (paz, acuerdo) y significaba, al principio, algo así como apaciguamiento o desligamiento del vínculo de la obligación.

II. En una etapa posterior se llamó pacto a todo lo que se conviniere en forma agregada a un contrato, y tenemos aquí la idea de los *pacta adiecta*.

Estos pactos se fueron estructurando por admisión pretoriana, que distinguía aquellos que se agregaban en el momento mismo de la celebración del contrato —*in continenti*— de aquellos que se agregaban con posterioridad —*ex intervallo*.

- * A su vez, había que distinguir si lo que se procuraba con estos pactos era aumentar (*augere*) la obligación —como, por ejemplo, estableciendo la solidaridad de los mutuarios— o si se procuraba disminuir (*minuere*) la obligación —como ocurre al establecer la posibilidad de pagos parciales al deudor.
- * Para este caso de disminución, el pretor seguirá la regla de equidad de otorgar al deudor una *exceptio pacti conventi* (excepción de pacto convenido) —como lo es el compromiso de no reclamar la deuda (*pactum de non petendo*)— o el otorgamiento de un plazo mayor. La regla del pretor era "*pacta conventa servabo*" ("haré respetar los pactos convenidos"). Por ello no distinguirá si son *in continenti* o *ex intervallo*.
- * Cuando se trataba de aumentar la obligación, era el acreedor el interesado en invocar esta circunstancia. Aquí había que distinguir —por lo menos en la época posclásica— entre los pactos agregados *in continenti* y los *ex intervallo*. Inicialmente se admitió la eficacia de los primeros en los contratos de buena fe, pero luego se los extendió a los demás; respecto de los segundos, no se aceptó su validez, entendiéndose que el agravamiento posterior del deudor significaba, siempre que fuese posible, la realización de un nuevo contrato.

En una acepción muy genérica, se acostumbró a llamar *pacta* o *conventiones* todos aquellos acuerdos que se formalizaban y que carecían de acción, oponiéndolos a los contratos, que sí la tenían. De ahí la denominación de *nuda pacta* (literalmente, pactos desnudos).

III. Sin embargo, hubo algunos pactos que merecieron la protección por parte del pretor. Ellos son los conocidos como *pacta praetoria*, que veremos por separado.

IV. A su vez, en la época de Justiniano se consideró que ciertos negocios, tales como las donaciones y las promesas de dote realizadas sin *stipulatio*, pudieran tener un carácter obligatorio autónomo. Son los *pacta legitima*.

V. Ya en la última época del derecho posclásico bizantino, al ponerse el acento en el *consensus* como elemento fundamental, tiende a borrarse la diferencia entre pactos y contratos.

PACTOS CON PROTECCION PRETORIANA

De estos pactos protegidos por *actiones in factum*, podemos comentar los siguientes.

CONSTITUTUM

El pacto de *constitutio* —vocablo proveniente de *constituere* (establecer [en este caso la concreción del pago])— es una convención por la cual una persona llamada *constituyente* se obliga —sin empleo de formas determinadas— a pagar deuda preexistente, ya sea su propia deuda (*constitutum debiti proprii*), ya sea una deuda ajena (*constitutum debiti alieni*).

- El interés de este pacto nace como un castigo a la persona que estando sujeta a una obligación, ha prometido por el *constitutum* abonarla en un plazo excedente. Al no cumplir se verá, ahora, enfrentada a la acción de *pecunia constituta*, según la cual la tasa de los daños e intereses que hubiera sido de sólo la tercera parte del capital, se elevará a la mitad del mismo —en el caso de haberse actuado por la *condictio certae pecuniae*.
- En el supuesto de *constitutum* de un crédito ajeno, tiene todas las características de una fianza por el mismo.

RECEPTA

El edicto del pretor relacionará tres pactos, cuya vinculación nace del nombre adoptado. En efecto, la palabra *receptum*

viene del verbo *recipere*, que quiere decir recibir, aceptar, encargarse de.

Se dan tres figuras típicas.

(A) *Receptum arbitrii*. Dos personas han decidido poner término a un diferendo encargando a un tercero para que, como árbitro imparcial, señale cuál de las dos tiene razón.

- El *receptum* es la aceptación del encargo de árbitro por parte del tercero comprometiéndose a llevar a buen término su cometido. El laudo que dicte será obligatorio para las partes, pudiendo el pretor forzarlas a cumplirlo sin necesidad de una *actio* o de sentencia.

(B) *Receptum argentarii*. Ocurre acá que un banquero (*argentarius*) se encarga de pagar la deuda de otro, generalmente la que va a contratar con un tercero.

- Como se puede apreciar, esta operación bancaria funciona de manera muy similar a la fianza, que se vio en el *constitutum debiti alieni*. La diferencia reside en que acá no se exige, como en aquél, una deuda preexistente.
- Por ello, el papel de este *receptum* es permitir fortificar el crédito de un cliente que está a punto de concluir un negocio importante. Servirá también para que un cliente del banquero pudiera efectuar un pago en una ciudad distinta.

(C) *Receptum nautarum, cauponum, stabularium*. Los navieros, posaderos y dueños de establos se encargan de las mercaderías, equipajes y animales que han recibido en sus naves, posadas o establos y que hayan sido destruidos o deteriorados, aun sin culpa suya, salvo que demostraren que los daños acaecieron por fuerza mayor.

- En un principio esta responsabilidad debía surgir de una expresa asunción de los riesgos por parte de los dueños de esos lugares.
- Posteriormente, debido a las malas prácticas de los *nautae, caupones* y *stabularii*, esta responsabilidad surgió efecto por la mera introducción de las cosas en dichos lugares.
- Cuando surgía por realización del personal interno, ello configuraba un *quasi ex delicto*.

LOS PACTOS LEGITIMOS

Eran convenciones que sólo tenían por objeto hacer nacer obligaciones a cargo de una sola de las partes y que fueron sancionadas por constituciones imperiales del Bajo Imperio, que otorgaron a estos supuestos una acción de derecho estricto, fundada sobre la ley: la *condictio ex lege*.

EL COMPROMISO

Es una convención por la cual dos personas se ponen de acuerdo para confiar a un árbitro la decisión de zanjar un litigio.

- Esta figura corresponde al *receptum arbitrii*, denominación que se relacionaba con el encargo del árbitro. El compromiso es, en cambio, la convención previa de arbitraje.
- En un principio, por regla general, se llegaba a éste por medio de una *stipulatio*, en la cual se señalaba una *poena* en dinero si no se cumplía la decisión del árbitro.
- Más tarde, Justiniano decidió que el compromiso resultaba obligatorio si estaba acompañado de un juramento de las partes y del árbitro. Mas como luego decidió prohibir el juramento, declaró que sólo sería válido si las partes habían dado su adhesión por escrito a la sentencia o no la habían atacado en el plazo de diez días.

LA INSTITUCION DE DOTE

Para prometer la dote era necesario realizar o la *dotis dictio* * o la *promissio dotis* *, que eran contratos formales, pero, en el año 428, los emperadores Teodosio II y Valentiniano determinaron que la simple promesa informal de dote, sin necesidad de *stipulatio* alguna, otorgaba fuerza obligatoria a la misma.

LA DONACION

Consiste en la convención adoptada entre dos partes, por la cual una de ellas atribuirá a la otra algo en forma gratuita.

- El objeto de la donación puede ser la transmisión de una cosa, o la constitución de un derecho real, la cesión de un crédito, el asumir una

obligación, etcétera. Lo importante es que haya un *animus donandi*, o sea, una intención de cumplir una liberalidad.

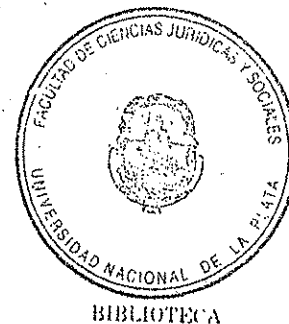
I. El Derecho Romano trató de muy distinta manera a las donaciones. Así, en un principio, los romanos desconfiaron de la transmisión de valores patrimoniales sin contraprestación, por lo que trataron a estos negocios en forma muy recelosa. Fruto de ello es la sanción de la *lex Cincia* (204 a.C.), la cual, además de prohibir a los abogados recibir dinero o regalos para pleitear, prohíbe hacer donaciones que pasen de un cierto monto, que nos es desconocido.

- Existen excepciones para familiares, por lo que se deduce que el propósito de la ley era evitar que el donador se empobreciera mediante liberalidades exageradas en favor de personas extrañas.
- Esta *lex* era imperfecta*; es decir, no indicaba la pena de nulidad ni de multa para las donaciones hechas en contra de los límites implantados. Por ello intervino el pretor concediendo la *exceptio legis Cinciae*, que permitirá al donante evitar que se logre por vía de acción la entrega de la cosa donada.
- Hacia el fin de la República, la costumbre había prohibido las donaciones entre esposos. Se temían los enriquecimientos logrados por la intervención de los sentimientos, así como también cuando, para impedir un divorcio, una de las partes intentara comprar la paz del hogar con dinero.
- Esta prohibición será atenuada en época de Caracalla (206 d.C.) al disponerse, por un senadoconsulto, que el esposo que recibiera la donación podía retener los objetos si el otro moría sin revocar el negocio.
- Además, por la *presumptio Muciana* que dictó Q. Mucius Scaevola, se determinó que cuando se dudara del origen de lo adquirido por la mujer casada, debía presumirse, salvo prueba en contrario, que provenía de su marido.

II. La donación, en el derecho clásico, no es considerada un negocio jurídico en sí mismo, sino solamente una *iusta causa* * —*causa donandi*— a los efectos de justificar una determinada apropiación patrimonial.

III. Sólo luego, con una ley de Constantino, se hará de la donación un negocio típico. Incluso se le prescribirá una determinada forma, exigiéndose, además de la entrega de la cosa, la redacción de un documento que debía ser inscripto en forma oficial (*insinuatio*). Cumplidos estos requisitos, operaba la transmisión de la propiedad.

IV. Finalmente, con Justiniano se llega a concebir la donación en una forma plena. Continuará funcionando como una *iusta causa* de adquisición; pero al mismo tiempo, la simple convención entre donante y donatario se transformará en un pacto legítimo, de tal modo que quedará el donante obligado a cumplir lo convenido.



CAPÍTULO XII

EFECTOS Y EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

Cuando se contrae una obligación, se produce para el acreedor una expectativa —la de cobrar la prestación debida— y para el deudor una responsabilidad —la de cumplir con aquello a lo cual se obligó.

Si hay cumplimiento, el nexo obligatorio quedará disuelto. Si no lo hay —ni se dan ninguna de las otras causas de extinción—, cabe analizar los efectos que provoca dicho incumplimiento.

El principio general determina que el deudor verá agravada su responsabilidad si el incumplimiento se produce por una causa imputable a su persona —caso del dolo o de la culpa— y deberá, incluso, responder del retardo en el cumplimiento —lo cual genera la *mora*—. Si el cumplimiento no se realiza, se abrirá la posibilidad para el acreedor de ejecutar la obligación, lo que en la época clásica se realiza generalmente mediante la venta pública del patrimonio (*bonorum venditio*) del deudor.

En virtud de la responsabilidad obligacional, la falta de cumplimiento en término determinará la agravación accesoria de los daños y perjuicios, que deberá abonar el deudor culpable al acreedor.